

<제01장 행정소송의 일반론.제02절 행정소송의 유형>

[예상][1.02-1]인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

《【문제1.2】

<사례>

A시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음1) 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 관련하여 우리 판례의 입장을 서술하고, 만약 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명하라.》

<문제1.2의 물음1> 인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 자신의 주거지 인근에 화장장 건립계획이 확정·발령되기 전에 그 시행을 금지하여 달라는 소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지> 여부와 <허용되지 않는 경우 甲이 취할 수 있는 다른 권리구제수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명한다.

II. 예방적 금지소송의 허용 여부

1. 예방적 금지소송의 의의

- 예방적 금지소송이란 행정청이 장래 일정한 처분을 할 것이 예상되는 경우에 미리 법원에 그 처분을 하여서는 안 된다는 명령을 구하는 소송을 말한다. 이는 행정권의 남용으로 인한 회복하기 어려운 손해를 미연에 방지하고자 하는 취지에서 논의된다.

2. 학설의 태도

(1) 긍정설

- 행정소송법 제4조의 항고소송 열거를 예시적인 것으로 보아, 국민의 재판청구권을 실질적으로 보장하고, 실효성 있는 권리구제를 위해 명문의 규정이 없더라도 예방적 금지소송을 인정해야 한다는 견해이다.

(2) 부정설

- 행정소송법 제4조는 항고소송의 종류를 한정적으로 규정한 것이며, 예방적 금지소송을 인정할 경우 행정권의 1차적 판단권을 침해하여 권력분립 원칙에 반하게 된다는 견해이다.

3. 판례의 입장

- 우리 대법원은 예방적 금지소송에 대하여 매우 엄격한 부정적 입장을 견지하고 있다. 판례는 행정소송법상 항고소송의 종류는 법에 명시된 것에 한정된다고 보며, 행정청의 처분이 내려지기 전에 미리 그 처분의 금지를 구하는 소송은 현행법상 허용되지 않는다고 판시한다.

(1) 판결의 주요 논거

- 대법원은 행정처분에 대한 사법심사는 행정청이 처분을 발령한 이후에 그 적법성을 판단하는 것이 원칙이라고 본다. 만약, 처분이 발령되기도 전에 법원이 이를 금지한다면 행정청의 고유한 권한을 사전에 제약하게 되어 권력분립의 원칙상 부당하다는 점을 강조한다.

(2) 구체적인 사례

- 판례는 화장장 건립 반대나 건축 허가 금지 청구 등과 같이 장래의 처분을 미리 저지하려는 청구에 대하여 소의 부적합을 이유로 각하판결을 내리고 있다. 즉, 주관적 권리구제의 필요성보다 행정의 자율성과 사법부의 사후 심사 원칙을 우선시키고 있다.

III. 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형 및 구제 수단

1. 처분 발령 이후의 항고소송

- 예방적 금지소송이 허용되지 않으므로 甲은 행정청의 화장장 건립 계획이 대외적으로 확정되어 처분의 형태로 발령될 때까지 기다려야 한다.

(1) 취소소송

- A시장의 화장장 건립 결정이 처분성을 갖추어 발령되면, 甲은 해당 처분이 자신의 법률상 이익을 침해함을 근거로 처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다. 이는 행정소송법 제4조 제1호에 따른 가장 전형적인 항고소송이다.

(2) 무효확인소송

- 만약, 해당 건립 계획 처분에 중대하고 명백한 하자가 존재하여 그 효력이 처음부터 발생하지 않았다고 판단되는 경우에는 무효확인소송을 제기하여 그 효력 유무를 다툴 수 있다.

2. 가구제 수단의 활용(집행정지)

- 사후적 소송만으로는 이미 진행된 공사 등으로 인해 甲의 권익이 침해될 위험이 크다. 따라서 본안 소송 제기과 동시에 집행정지를 신청하여 실효성을 확보할 수 있다.

(1) 집행정지의 요건

- 甲은 취소소송 또는 무효확인소송을 제기한 상태에서, 처분의 집행이나 효력의 정지가 없으면 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고, 긴급한 필요가 있다는 점을 소명해야 한다.

(2) 집행정지의 효과

- 법원이 甲의 신청을 인용하여 집행정지 결정을 내리면, 본안 판결 시까지 화장장 건립 계획의 효력이나 그에 따른 공사 집행이 일시적으로 정지된다. 이는 예방적 금지소송의 실질적인 대안 역할을 한다.

IV. 사안의 적용

- 사안에서 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송은 판례에 따르면 현행 행정소송법상 허용되지 않는다. 따라서 甲이 계획 단계에서 제기하는 금지소송은 각하될 가능성이 크다.

1. 소송의 부적법성

- 甲의 청구는 행정청의 1차적 판단권을 침해하고, 법적 근거가 없는 소송 유형이므로 판례상 부적법하다.

2. 대안적 권리구제

- 甲은 화장장 건립 계획이 처분으로서 발령된 직후에 취소소송을 제기해야 한다. 또한, 처분의 효력을 즉시 멈추기 위해 집행정지를 신청함으로써 건립 중단이라는 실질적인 목적을 달성할 수 있다.

3. 관련 이익의 검토

- 甲은 인근 주민으로서 환경상 이익 등 법률상 이익을 가지는 제3자에 해당하므로 원고적격을 인정받는 데 어려움이 없을 것이며, 처분 발령 후 적법한 기간 내에 소를 제기해야 한다.

V. 결론

- 결론적으로 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송은 우리 판례상 허용되지 않는다. 甲은 향후 행정청이 건립 계획을 처분으로 발령하면 그에 대하여 취소소송을 제기하고, 이와 병행하여 집행정지 신청을 함으로써 권리를 구제받아야 한다. 이러한 판례의 태도는 행정의 능동적 수행을 보장하기 위한 것이나, 국민의 권익 보호를 위해 향후 행정소송법 개정 등을 통해 예방적 금지소송의 도입을 검토할 필요가 있다는 점이 중요하게 다루어진다.

<제01장 행정소송의 일반론.제02절 행정소송의 유형>

[예상][1.02-2]공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

《【문제1.2】

<사례>

A시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음2) 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형(항고소송 vs 당사자소송)을 판례의 입장에 근거하여 구분하고, 그 이유를 기술하라.》

<문제1.2의 물음2> 공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

I. 문제의 제기

- 사안에서 공무원 乙은 자신에게 내려진 정직 처분이 무효임을 전제로 하여, 이미 발생하였으나 지급되지 않은 보수의 지급을 청구하는 소송을 제기하고자 한다. 이때 <乙이 제기해야 하는 소송이 처분 등의 취소나 무효확인을 구하는 항고소송인지, 아니면 공법상 법률관계에 관한 다툼을 다루는 당사자소송인지>가 문제된다. 이하에서는 공무원의 보수청구권의 법적 성질과 관련한 판례의 입장을 토대로 소송 유형을 구분하고 그 이유를 구체적으로 기술한다.

II. 보수 청구 소송의 유형 검토

1. 항고소송과 당사자소송의 구분

(1) 항고소송

- 행정청의 처분등 공법적 권력 행사의 취소나 무효확인을 구하는 소송이다. 행정청의 처분이 있어야만 비로소 구체적인 권리가 발생하는 경우라면, 해당 처분을 다루는 항고소송의 형태를 띠게 된다.

(2) 당사자소송

- 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 공법상 신분이나 계약, 또는 법령의 규정에 의하여 당연히 발생하는 권리라면 당사자소송의 대상이 된다.

2. 판례의 입장

(1) 보수청구권 발생 근거에 따른 구분

- 우리 판례는 공무원의 보수청구권이 법령의 규정에 의하여 직접 그 존부나 범위가 확정되는 경우에는 행정청의 별도 처분을 거칠 필요 없이 직접 당사자소송으로 그 지급을 구할 수 있다는 입장이다. 즉, 보수 지급 여부가 행정청의 재량이나 처분에 달린 것이 아니라 법령에 의해 일률적으로 정해져 있다면 이는 처분에 대한 다툼이 아닌 법률관계 자체에 대한 다툼으로 본다.

(2) 징계처분 무효와 보수청구권

- 판례에 의하면 정직 처분과 같은 징계처분이 무효인 경우, 그 처분은 처음부터 효력이 없었던 것이 되므로 공무원의 신분 및 법령상 보수청구권은 중단 없이 유지된다. 따라서 무효인 처분을 원인으로 하여 이미 발생한 미지급 보수를 청구하는 것은 공법상 법률관계에 관한 다툼으로서 당사자소송의 영역에 속한다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형의 결정 : 당사자소송

- 乙은 정직 처분의 무효를 전제로 보수 지급을 청구하고 있다. 공무원의 보수는 공무원보수규정 등 관련 법령에 의해 지급 요건과 범위가 확정되어 있다. 정직 처분이 당연무효라면 乙은 법령상 당연히 해당 기간의 보수청구권을 보유하게 되므로, 이는 행정청의 새로운 보수 지급 처분을 기다릴 필요 없이 국가나 지방자치단체를 상대로 한 당사자소송으로 제기해야 한다.

2. 항고소송이 부적절한 이유

- 乙이 정직 처분 자체의 효력을 없애고자 한다면 무효확인소송(항고소송)을 제기할 수 있으나, 본 사안의 직접적인 목적은 미지급된 보수의 지급이라는 구체적인 금전적 청구권의 행사이다. 보수 지급 행위는 행정청의 공권력 행사인 처분이 아니라 법령상 의무 이행인 공법상 법률관계의 이행에 해당하므로 항고소송인 취소소송이나 무효확인소송의 대상이 될 수 없다.

3. 소송의 구조 및 선결문제

- 乙은 보수 지급 의무가 있는 주체를 피고로 설정하여 당사자소송을 제기하여야 한다. 이 경우 수소법원은 해당 당사자소송의 선결문제로서 정직 처분의 무효 여부를 스스로 판단할 수 있으며, 무효라고 판단될 경우 피고에게 보수 지급을 명하는 판결을 내리게 된다.

IV. 결론

- 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송 유형은 당사자소송이다. 판례는 법령상 당연히 발생하는 공무원의 보수청구권을 공법상 법률관계에 관한 권리로 판시하고 있다. 따라서 행정청의 별도 처분 없이도 당사자소송을 통해 직접 지급 청구가 가능하다. 이는 행정소송의 효율적인 분류와 국민의 실질적인 금전적 권리 구제를 도모하는 판례의 확립된 태도에 부합한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제01절 소송요건의 일반론>

[예상][2.01-1]취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

《【문제2.1】

<사례>

A시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 폐기물 관리법 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음1) 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술하라.》

<문제2.1의 물음1> 취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 사업장 폐쇄명령의 취소를 구하는 취소소송을 제기하고자 하고, 법원은 소송을 심리하는 과정에서 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지 등 소송요건의 구비 여부를 문제 삼고 있다. 쟁점으로 <취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질과 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위하여 직권으로 조사할 수 있는 사항의 원칙 및 예외>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술한다.

II. 취소소송 소송요건의 법적 성질

1. 소송의 적법요건

- 취소소송의 소송요건은 법원이 본안 심리에 들어가기 위해 반드시 갖추어야 할 전제조건이다. 이러한 소송요건을 갖추지 못한 소 제기는 부적법한 것이 되어 본안 판결(인용 또는 기각)을 내릴 수 없으며, 법원은 판결으로써 소를 각하해야 한다.

2. 재판상의 요건

- 소송요건은 소 제기 당시는 물론 변론 종결 시까지 계속해서 존재해야 한다. 만약, 소 제기 당시에는 요건을 갖추었더라도 소송 도중에 요건이 흠결되게 되면 법원은 소를 각하해야 한다. 반대로 소 제기 당시에는 흠결이 있었으나 각하되지 않고, 본안 심리가 진행되었다면 변론 종결 전까지 흠결이 치유되면 적법한 소가 된다.

3. 강행규정성

- 행정소송법상의 소송요건은 공익적 견지에서 정해진 강행규정이다. 따라서 당사자 사이의 합의로 소송요건의 흠결을 정당화하거나 면제할 수 없으며, 법원은 당사자의 주장 여부와 상관없이 이를 엄격히 심사해야 한다.

III. 직권조사 사항의 원칙과 예외

1. 직권조사의 원칙

(1) 의의

- 소송요건의 존부는 법원의 직권조사 사항에 해당한다. 이는 소송의 개시와 범위는 당사자의 의사에 맡기지만, 일단 개시된 소송이 적법한지 여부에 대한 판단은 사법 정의의 실현과 공익 보호를 위해 법원의 고유한 권한이자 의무로 보는 것이다.

(2) 법원의 의무

- 법원은 당사자가 소송요건의 흠결을 주장하지 않더라도 스스로 이를 조사하여 확인해야 할 의무가 있다. 만약, 피고인 행정청이 소송요건에 대해 아무런 이의를 제기하지 않더라도 법원은 대상적격이나 제소기간 등의 준수 여부를 독립적으로 심사해야 한다.

(3) 증명책임의 소재

- 소송요건의 구비 사실에 대한 증명책임은 원칙적으로 소를 제기한 원고에게 있다. 원고는 자신이 제기한 소가 적법함을 소명해야 하며, 법원이 직권으로 조사함에 있어 필요한 자료를 제출할 협조 의무를 진다.

2. 직권탐지주의의 예외적 적용

(1) 행정소송법 제26조와의 관계

- 행정소송법 제26조는 법원이 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대해서도 판단할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 민사소송법상의 변론주의를 보완하여 행정처분의 적법성 확보라는 공익을 달성하기 위함이다.

(2) 직권조사와 직권탐지의 차이

- 직권조사는 판단의 기초가 되는 자료가 제출되어 있을 때 법원이 이를 스스로 검토하는 것을 의미하며, 직권탐지는 법원이 직접 증거를 수집하고 당사자가 주장하지 않은 사실까지 찾아내는 적극적인 행위를 포함한다. 판례는 소송요건에 관하여 사실관계의 존부가 불분명한 경우 법원이 적극적으로 이를 탐지하여 확인할 수 있다는 태도를 취한다.

(3) 보정 명령

- 법원은 소송요건의 흠결이 발견되었으나 그것이 보정 가능한 성질의 것인 경우, 즉시 각하하기보다는 원고에게 보정을 명하여 국민의 재판청구권을 실효적으로 보장해야 한다. 예를 들어 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정 등을 유도하는 것이 이에 해당한다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송요건 검토

- 법원은 甲이 제기한 취소소송에서 A시장의 사업장 폐쇄 명령이 행정소송법상 처분에 해당하는지(대상적격), 甲이 해당 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지(원고적격), 그리고 제소기간 내에 소를 제기했는지 등을 직권으로 조사해야 한다.

2. 법원의 직권조사 수행

- 본 사안에서 법원은 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 가졌으므로, 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 관련 법령과 사실관계를 조사하여 대상적격 유무를 판단해야 한다. 만약, 사업장 폐쇄 명령이 폐기물 관리법에 근거한 구체적 사실에 대한 법집행으로서 공권력의 행사임이 확인된다면 처분성이 인정될 것이다.

V. 결론

- 취소소송의 소송요건은 소의 적법 여부를 결정하는 강행규정적 성격을 가지며, 법원의 직권조사 사항이다. 법원은 당사자의 항변 유무와 관계없이 소송요건의 구비 여부를 확인해야 하며, 필요시 직권으로 자료를 탐지할 수 있다. 甲의 소송에서 법원은 사업장 폐쇄 명령의 처분성을 직권으로 심사하여 소의 적법성을 먼저 가려낸 후 본안 심리에 임해야 한다. 이러한 법리는 행정소송이 단순히 개인의 이익 보호를 넘어 행정의 적법성 통제라는 공익적 기능을 수행하고 있음을 뒷받침한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제01절 소송요건의 일반론>

[예상][2.01-2]권고조치를 대상으로 한 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

《【문제2.1】

<사례>

A시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 폐기물 관리법 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음2) 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 소송요건으로서 어떠한 의미를 갖는지 기술하고, 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 내려야 하는 판결의 종류와 그 사유를 설명하라.》

<문제2.1의 물음2> 권고조치 대상 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청의 처분이 아닌 사실상의 행정지도인 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 이때 <乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 어떠한 법적 의미를 갖는지> 검토가 필요하다. 또한 <취소소송의 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 어떠한 판결을 내려야 하는지>와 그 사유를 명확히 규명해야 한다. 이하에서는 대상적격의 의의와 소송요건 흠결 시의 판결인 각하판결에 대해 설명한다.

II. 대상적격의 의미와 乙의 소송에서의 중요성

1. 대상적격의 의의

- 대상적격이란 행정소송의 대상이 될 수 있는 적절한 자격을 의미한다. 행정소송법 제2조 제1항 제1호 및 제19조에 따라 취소소송의 대상은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용인 처분등이어야 한다.

2. 乙의 소송에서 대상적격의 의미

(1) 소송의 적법성 판단 기준

- 乙이 다투고자 하는 권고 조치는 원칙적으로 행정지도에 해당한다. 행정지도는 상대방의 임의적 협력을 전제로 하는 비권력적 사실행위로서, 국민의 권리와 의무에 직접적인 법적 변화를 일으키지 않으므로 처분성이 부정되는 것이 원칙이다. 따라서 乙의 소송에서 대상적격의 존부는 해당 소송이 본안 심리로 나아갈 수 있는지 여부를 결정하는 핵심적인 관문이 된다.

(2) 항고소송의 범위 확정

- 대상적격은 사법권에 의한 행정통제의 범위를 확정하는 기능을 한다. 권고 조치가 예외적으로 처분성을 인정받지 못한다면, 이는 행정소송의 대상이 될 수 없음을 의미하며 사법부가 개입할 수 없는 영역으로 남게 된다.

III. 소송요건 결여 시의 판결 유형 : 각하판결

1. 각하판결의 의의

- 각하판결이란 소송요건이 흠결되어 소송이 부적법한 경우, 본안(처분의 위법성 여부)에 대하여 판단하지 않고 소송을 종결시키는 판결을 말한다. 이는 소송의 개시를 거절하는 소송판결의 일종이다.

2. 각하판결의 사유

(1) 소송요건의 불비

- 취소소송이 적법하기 위해 갖추어야 할 대상적격, 원고적격, 협의의 소의, 피고적격, 제소기간, 행정심판 전치주의 등의 요건 중 어느 하나라도 결여된 경우이다. 사안의 乙처럼 처분성이 없는 행정지도를 대상으로 소를 제기한 경우 대상적격 흠결이 각하 사유가 된다.

(2) 보정의 불가능 또는 불이행

- 흠결된 소송요건이 보정할 수 없는 것이거나, 법원의 보정 명령에도 불구하고 원고가 이를 보정하지 않은 경우 법원은 각하판결을 내린다. 행정지도를 대상으로 한 소송은 처분성이라는 본질적 요건의 흠결로 보정이 불가능한 경우가 많다.

IV. 사안의 적용

1. 乙이 제기하려는 소송의 대상적격 검토

- 乙이 다투고자 하는 권고 조치는 사례에서 사실상의 행정지도에 불과한 것으로 명시되어 있다. 판례에 따르면 행정지도는 공권력의 행사가 아니므로 취소소송의 대상인 처분에 해당하지 않는다. 따라서 乙의 소송은 대상적격이라는 소송요건을 결여하고 있다.

2. 법원이 내려야 하는 판결 : 각하판결

- 법원은 乙이 제기한 소송을 심리함에 있어 직권조사 사항인 대상적격 유무를 먼저 확인해야 한다. 조사 결과 권고 조치의 처분성이 부정되므로, 법원은 본안 심리인 영업상 손실의 위법성 여부를 판단할 필요 없이 소송법적 판단만으로 소를 각하해야 한다.

3. 각하판결의 사유

- 乙의 소송은 행정소송법 제2조 및 제19조가 정한 처분을 대상으로 하지 않았으므로 대상적격을 갖추지 못하였다. 이러한 소송요건의 흠결은 강행규정 위반으로 부적법한 소 제기해 해당하며, 사법 자원의 효율적 배분과 행정권의 독립성 존중을 위해 법원은 각하판결로써 소송을 종결시켜야 한다.

V. 결론

- 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격은 소의 적법성을 결정짓는 필수적인 소송요건이다. 행정지도에 불과한 권고 조치는 처분성이 부정되므로 乙의 소송은 대상적격을 결여한 부적법한 소에 해당한다. 법원은 이러한 소송요건의 흠결을 이유로 본안 판단을 거절하는 각하판결을 내려야 한다. 이러한 법리는 국민의 권리구제와 행정작용의 처분성 사이의 한계를 명확히 함으로써 행정소송의 적법한 범위를 확정하는 데 기여한다.

《【문제3.4】

<사례>

A시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음1) 사업 시행자 甲이 소송 계속 중 자신의 이익을 보호하기 위해 취할 수 있는 행정소송법상 조치와 그 요건에 대하여 서술하시오.》

<문제3.4의 물음1> 폐기물 처리시설 설치 승인 처분의 수익자인 회사가 취소소송에 참가하기 위한 요건과 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 사업 시행자인 甲 주식회사는 폐기물 처리시설 설치 승인처분에 대한 취소소송이 계속 중 그 소송 결과로 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 쟁점으로 <사업 시행자인 甲이 자신의 이익을 보호하기 위하여 행정소송법상 어떠한 소송참가를 할 수 있는지와 그 요건>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 사업 시행자 甲이 소송 계속 중 자신의 이익을 보호하기 위해 취할 수 있는 행정소송법상 조치와 그 요건에 대하여 서술한다.

II. 제3자의 소송참가

1. 소송참가의 의의

- 소송참가란 소송 계속 중 당사자 이외의 제3자가 자기의 법률상 이익을 보호하기 위하여 또는 당사자 일방을 보조하기 위하여 해당 소송 절차에 가입하는 것을 말한다. 이는 소송의 결과에 의하여 영향을 받는 제3자에게 소송참여의 기회를 부여함으로써 그 권익을 보호하고 판결의 모순을 방지하여 분쟁을 일거에 해결하는 데 목적이 있다.

2. 소송참가의 요건

(1) 소송의 계속

- 소송참가는 사실심의 변론종결 전까지 소송이 계속되어 있어야 한다. 상고심에서의 소송참가 가능성에 대해서는 견해가 대립하나 판례는 상고심에서도 소송참가가 가능하다고 보고 있다.

(2) 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자

- 판례에 의하면 여기서 소송의 결과란 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중의 판단까지 포함하며 권리 또는 이익의 침해란 당해 처분의 취소 판결로 인하여 자신의 법률상 이익이 침해되는 경우를 의미한다. 사안의 甲은 처분의 상대방으로서 처분이 취소될 경우 직접적으로 법률적 불이익을 입게 되므로 이에 해당함이 명백하다.

(3) 참가의 필요성

- 제3자가 자신의 권익을 보호하기 위하여 소송 절차에 가입하여 자기의 의견을 진술하고 증거를 제출할 필요가 있어야 한다.

3. 참가의 절차 및 방법

(1) 신청 또는 직권에 의한 결정

- 소송참가는 당사자나 제3자의 신청 또는 법원의 직권에 의한 결정으로 이루어진다. 제3자가 신청하는 경우 참가의 이유를 명시하여 서면으로 제출해야 한다. 법원은 결정을 내리기 전에 당사자와 제3자의 의견을 들어야 한다.

(2) 참가인의 지위

- 참가인은 독립하여 소송행위를 할 수 있는 지위를 갖는다. 다만 피참가인인 행정청의 소송행위와 저촉되는 행위는 할 수 없으나 참가인의 이익이 피참가인과 반드시 일치하는 것은 아니므로 독자적인 증거 제출이나 주장 제기가 가능하다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 지위 및 참가 가능성

- 사안에서 甲 주식회사는 A시 시장으로부터 폐기물 처리시설 설치 승인을 받은 처분의 직접 상대방이다. 주민 乙이 제기한 취소소송에서 乙이 승소할 경우 甲의 설치 승인 처분은 효력을 상실하게 되어 사업 수행이 불가능해진다. 이는 소송의 결과에 따라 법률상 이익의 침해를 받는 제3자에 해당하므로 행정소송법 제16조에 따른 소송참가 요건을 충족한다.

2. 구체적 조치

- 甲은 현재 소송이 계속 중인 법원에 소송참가신청서를 제출하여야 한다. 신청서에는 취소소송의 결과로 인해 자신이 입게 될 불이익과 참가의 필요성을 상세히 기재하여야 한다. 법원이 참가를 허가하는 결정을 내리면 甲은 소송당사자에 준하는 지위에서 해당 처분의 적법성을 옹호하는 주장을 펼치고 관련 증거를 제출함으로써 자신의 이익을 방어할 수 있다.

3. 소송 행위의 범위

- 참가인으로 확정된 甲은 독자적으로 상소하거나 재심청구를 할 수 있는 권한을 가지며 원고 乙의 주장에 대항하여 처분의 절차적 정당성(환경영향평가법 준수 여부 등)을 적극적으로 변론할 수 있다. 특히 피참가인인 행정청이 소홀히 할 수 있는 수익적 처분의 신뢰보호 필요성 등을 주장함으로써 재판부의 판단에 영향을 미칠 수 있다.

IV. 결론

- 사안의 사업 시행자 甲은 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 직접적으로 침해될 우려가 있는 제3자이다. 따라서 행정소송법 제16조에 의거하여 해당 취소소송이 계속 중인 법원에 소송참가를 신청할 수 있다. 법원의 참가 결정이 내려지면 甲은 참가인으로서 독자적인 소송수행권을 행사하며 판결의 결과에 따른 불이익을 방지할 수 있는 법적 기회를 보장받게 된다. 이러한 소송참가는 절차적 권리 보장을 넘어 판결의 실효성을 높이고 관련 분쟁의 일회적 해결을 가능케 하는 중요한 수단이 된다.

《【문제3.4】

<사례>

A시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음2) 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토하시오.》

<문제3.4의 물음2> 인근 주민의 취소소송 참가 가능성 및 행정소송법 제16조상 참가인의 법적 지위

I 문제의 제기

- 사안에서 인접 지자체 주민인 丙은 폐기물 처리시설 설치 승인처분의 취소를 구하는 乙의 소송에서 환경상 피해를 우려하여 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참가하고자 한다. 쟁점으로 <주민 丙에게 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 인정되는지>와 <참가가 인정될 경우 참가인의 지위를 어떻게 보는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토한다.

II 제3자 소송참가의 요건과 丙의 참가 가능성

1. 제3자의 법률상 이익

(1) 법률상 이익의 의미

- 행정소송법 제16조의 법률상 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 말하며, 단순히 간접적이거나 사실적·경제적 이해관계를 가지는 경우에는 포함되지 않는다.

(2) 환경권과 법률상 이익

- 판례는 환경영향평가 대상 지역 내의 주민들에 대해서는 환경상 이익의 침해를 법률상 이익으로 추정한다. 그러나 대상 지역 밖의 주민이라 하더라도 당해 처분으로 인하여 환경상 이익을 침해받거나 침해받을 우려가 있음을 입증하는 경우에는 법률상 이익을 인정한다.

2. 소송의 결과와의 관련성

- 소송의 결과란 판결의 주문뿐만 아니라 그 전제가 되는 이유 중의 판단까지 포함한다. 제3자의 권리나 이익이 당해 소송의 판결에 의해 직접 영향을 받는 관계에 있어야 한다.

3. 사안의 경우

- 丙은 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 주민이다. 丙이 환경영향평가 대상 지역 내에 거주한다면 법률상 이익이 당연히 인정되나, 지역 밖에 거주한다면 수인한도를 넘는 환경상 피해를 구체적으로 입증해야 한다. 만약 丙에게 이러한 법률상 이익이 인정된다면 乙이 승소할 경우 처분이 취소되어 丙의 환경상 이익이 보호되므로 소송의 결과에 이해관계를 가진 제3자로서 참가 요건을 충족할 수 있다.

III 소송참가인의 법적 지위

1. 독립적 지위의 인정 여부

- 행정소송법 제16조에 의해 참가한 제3자는 단순한 보조참가인과 달리 당사자에 준하는 독립된 지위를 갖는다. 이는 판결의 효력이 제3자에게도 미치는 제3자효(형성력)가 있기 때문이다.

2. 소송행위의 범위

(1) 독자적인 소송행위

- 참가인은 자기의 이름으로 소송행위를 할 수 있다. 기일의 통지를 받고 변론에 참여하여 독자적인 증거를 제출하거나 공격·방어 방법을 제시할 수 있다.

(2) 피참가인과의 관계

- 참가인은 피참가인(원고 乙)의 소송행위와 저촉되는 행위를 할 수 있다. 즉, 원고가 주장하지 않는 사유를 주장하거나 원고가 제출하지 않은 증거를 제출할 수 있다. 다만, 소의 취하나 포기 등 소송물 자체를 처분하는 행위는 허용되지 않는다.

(3) 상소 및 재심청구

- 참가인은 소송 결과에 대하여 독자적으로 상소할 수 있으며, 확정판결에 대하여 행정소송법 제31조에 따른 제3자의 재심청구권을 행사할 수 있는 주체가 된다.

3. 민사소송법상 공동소송적 보조참가와와의 비교

- 행정소송법상의 제3자 소송참가는 판결의 효력이 참가인에게 미친다는 점에서 민사소송법상의 공동소송적 보조참가와 유사한 지위를 갖는다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

IV 사안의 적용

1. 丙의 참가 유형 검토

- 丙은 원고 乙의 승소를 보조하기 위해 참가하고자 하므로, 실질적으로는 원고 측 제3자 소송참가인이 된다. 丙의 거주지가 환경영향평가법령에 의해 보호되는 범위 내에 있거나, 범위를 벗어나더라도 수인한도를 넘는 피해를 입증할 수 있다면 丙은 행정소송법 제16조의 제3자로서 소송참가가 가능하다.

2. 丙의 지위와 권한

- 丙이 소송에 참가하면 乙의 소송수행 능력과 관계없이 독자적으로 환경 오염의 위험성을 입증할 자료를 법원에 제출할 수 있다. 설령 원고 乙이 소송에 소극적으로 임하더라도 丙은 자신의 환경상 이익을 지키기 위해 적극적으로 변론할 수 있으며, 1심 판결에서 乙이 패소한 경우 乙이 항소하지 않더라도 丙은 독자적으로 항소하여 소송을 계속할 수 있는 지위를 보장받는다.

V. 결론

- 주민 丙이 환경상 피해 우려를 구체적으로 입증하여 법률상 이익을 인정받는다면 행정소송법 제16조에 따른 제3자의 소송참가가 가능하다. 이때 丙은 단순한 보조자가 아니라 당사자에 준하는 공동소송적 보조참가인의 지위를 갖게 된다. 이를 통해 丙은 원고 乙의 소송행위에 구애받지 않고 자신의 독립된 이익을 보호하기 위한 모든 소송행위를 수행할 수 있으며, 이는 행정소송의 적정성과 실효적 권리 구제를 보장하는 중요한 장치가 된다.

《【문제5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 식품위생법 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 미성년자에게 주류를 제공하였다는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음1) 행정청 A가 소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 사유를 추가하거나 변경하는 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술하라.》

<문제5.1의 물음1> 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대한 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A는 영업정지처분의 취소소송 계속 중 처분서에 기재되지 않았던 새로운 위반사실을 처분사유로 추가하여 처분의 적법성을 주장하고자 한다. 쟁점으로 <소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 처분사유의 추가·변경이 허용되는지>와 <그 허용범위 및 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술한다.

II. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 인정 여부

1. 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 처분 당시에 적시한 사유 외에 소송 계속 중에 새로운 사유를 추가하거나 당초의 사유를 다른 사유로 변경하여 처분의 적법성을 주장하는 것을 말한다.

2. 인정 여부에 관한 판례의 입장

- 명문의 규정이 없음에도 불구하고 판례는 소송경제와 행정의 적법성 확보라는 측면에서 일정한 한계 내에 처분사유의 추가·변경을 허용하고 있다. 다만 무제한적으로 허용할 경우 원고의 방어권을 침해할 수 있으므로 엄격한 요건을 요구한다.

III. 처분사유 추가·변경의 요건과 한계

1. 시간적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시 이미 존재하고 있었던 사유여야 한다. 처분 이후에 발생한 새로운 사실이나 법령의 변경을 근거로 당초 처분의 적법성을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 처분 시를 기준으로 사유의 존부를 판단해야 한다.

2. 객관적 한계 : 기본적 사실관계의 동일성

(1) 동일성 판단 기준

- 대법원은 당초의 처분사유와 추가·변경하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 경우에만 처분사유의 추가·변경을 허용한다. 여기서 동일성이란 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실관계에 비추어 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 의미한다.

(2) 판례의 구체적 경향

- 판례는 사실관계의 동일성 여부를 엄격하게 해석한다. 예를 들어 미성년자 주류 제공과 영업소 면적 변경 미신고는 그 기초가 되는 사실관계가 전혀 다르므로 동일성을 인정하기 어렵다. 반면 법적 근거 규정만을 변경하거나, 사실관계의 세부적인 부분만을 수정하는 경우에는 동일성을 인정하여 추가·변경을 허용하는 경향이 있다.

3. 절차적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 원고의 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다. 따라서 사실심 변론종결 전까지 이루어져야 하며, 당사자에게 충분한 반박 기회가 주어져야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 기본적 사실관계의 동일성 검토

- 행정청 A가 당초 내세운 사유인 미성년자 주류 제공은 영업 행위 상의 의무 위반에 해당하며, 새로 발견한 영업소 면적 변경 미신고는 영업 신고 사항의 변경이라는 형식적 의무 위반에 해당한다. 이 두 사실은 사회적 사실관계의 기초가 완전히 상이하므로 판례의 기준에 따를 때 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는다.

2. 추가·변경의 허용 여부 판단

- 사안의 경우 시간적 요건은 갖추었을지라도 객관적 요건인 동일성이 흠결되어 있다. 따라서 행정청 A가 소송에서 영업소 면적 변경 미신고 사유를 추가하거나 변경하여 처분의 정당성을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 만약 행정청이 해당 사유를 근거로 처분을 유지하고자 한다면, 현재 진행 중인 소송과 별개로 새로운 처분 절차를 밟아야 한다.

V. 결론

- 대법원 판례에 따르면 처분사유의 추가·변경은 당초 사유와 추가 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 예외적으로 허용된다. 사안의 미성년자 주류 제공과 면적 변경 미신고는 그 동일성이 인정되지 않으므로 행정청 A의 주장은 소송에서 받아들여질 수 없다. 이러한 판례 태도는 행정처분의 상대방인 원고가 소송에서 예측하지 못한 불이익을 당하는 것을 방지하고 재판받을 권리를 실질적으로 보호하기 위한 취지에서 확립된 법리라 할 수 있다.

《【문제5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 식품위생법 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 미성년자에게 주류를 제공하였다는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음2) 甲이 행정심판 단계의 기록을 법원이 제출받도록 하기 위해 활용할 수 있는 행정심판기록 제출명령의 의의와 그 효과에 대하여 설명하라.》

<문제5.1의 물음2> 행정심판기록 제출명령의 의의와 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 취소소송에서 자신에게 유리한 증거를 확보하기 위하여 행정청 A가 보관하고 있는 행정심판 단계의 기록을 법원에 제출받고자 한다. 쟁점으로 <행정심판기록 제출명령의 의의와 요건 및 그에 따른 법적 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판기록 제출명령의 의의와 그 효과에 대하여 설명한다.

II. 행정심판기록 제출명령의 의의 및 성질

1. 의의

- 행정심판기록 제출명령이란 행정소송의 제기가 있는 경우 법원이 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 행정심판을 행한 행정청에 대하여 행정심판에 관한 기록을 제출할 것을 명하는 제도를 말한다. 이는 행정청이 독점하고 있는 정보를 법원이 제출받게 함으로써 무기대등의 원칙을 실현하기 위한 장치이다.

2. 법적 성질

(1) 증거조사의 특례

- 민사소송법상의 문서제출명령이나 문서송부촉탁 등 일반적인 증거조사 방법이 행정소송에도 준용되지만, 행정심판기록 제출명령은 행정소송의 특수성을 고려하여 행정소송법 제25조가 별도로 마련한 특례 규정이다.

(2) 신청에 의한 결정

- 법원이 직권으로 명할 수는 없으며 반드시 당사자의 신청이 있어야 한다. 법원은 당사자의 신청이 이유 있다고 인정할 때 결정으로 제출을 명하게 된다.

III. 행정심판기록 제출명령의 요건 및 절차

1. 신청의 요건

(1) 행정심판을 거친 사건일 것

- 당해 처분에 대하여 행정심판을 거친 경우에만 신청이 가능하다. 사안의 甲은 행정심판 단계를 거쳤으므로 이 요건을 충족한다.

(2) 소송이 계속 중일 것

- 취소소송 등 항고소송이 법원에 적법하게 제기되어 소송이 계속되고 있는 상태여야 한다.

2. 제출의 대상

- 행정심판 기록에는 청구서, 답변서, 심리조서, 증거서류 및 의결서 등이 포함된다. 행정청은 법원의 명령이 있으면 해당 기록 전부 또는 일부를 지체 없이 법원에 제출하여야 한다.

IV. 행정심판기록 제출명령의 효과

1. 증거자료의 확보와 심리의 충실화

(1) 정보 비대칭의 해소

- 행정처분의 근거가 되는 조사 자료나 심판 과정의 진술은 주로 행정청이 보관하고 있어 원고가 접근하기 어렵다. 제출명령을 통해 이러한 자료가 법원에 제출됨으로써 원고인 甲은 자신에게 유리한 증거를 확보할 수 있고, 법원은 처분의 위법성 여부를 더욱 정확하게 판단할 수 있다.

(2) 사실관계의 명확화

- 행정심판 단계에서 다투어졌던 사실관계와 행정청의 판단 근거가 소송에서 그대로 드러나게 되므로, 쟁점을 조기에 확정하고 심리를 신속하고 충실하게 진행할 수 있는 효과가 있다.

2. 불이행 시의 효과

(1) 증거법적 불이익

- 행정청이 법원의 제출명령에 정당한 사유 없이 응하지 않는 경우, 법원은 민사소송법을 준용하여 원고인 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정하거나 행정청에게 불리한 사실인정을 할 수 있는 자유심증권의 행사가 가능해진다.

(2) 심리의 방해에 대한 판단

- 공법상 의무를 지는 행정청이 사법부의 명령을 거부하는 것은 행정의 적법성 원칙에 반하는 행위로 간주되어 소송 결과에 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 甲의 권리구제 수단으로서의 효용성

- 甲은 행정심판 기록 중 조사 자료를 통해 '미성년자 주류 제공' 사실이 없었음을 증명하거나, 행정청 A의 적법절차 위반 등을 입증할 수 있다. 특히 행정청 A가 주장하려는 새로운 사유인 '면적 변경 미신고'가 처분 당시에 전혀 고려되지 않았음을 심판 기록을 통해 확인하여 처분사유의 추가·변경의 부당성을 논증하는 데 활용할 수 있다.

2. 법원의 판단 근거 제공

- 법원은 제출된 기록을 바탕으로 행정청 A의 처분이 식품위생법상 적법한 절차와 근거를 갖추었는지 심리하게 된다. 甲이 주장하는 유리한 증거들이 기록에 포함되어 있다면 이는 甲의 승소 가능성을 높이는 결정적인 역할을 할 것이다.

Ⅵ. 결론

- 행정심판기록 제출명령은 행정소송에서 원고와 피고 사이의 정보 불균형을 시정하고 실질적인 법치주의를 구현하기 위한 필수적인 제도이다. 甲은 법원에 행정심판기록 제출명령을 신청함으로써 행정청이 독점하고 있는 증거 자료를 법정에 현출시킬 수 있으며, 이를 통해 처분의 위법성을 효과적으로 공격하고 자신의 권익을 보호받을 수 있다.

<제07장 취소소송의 가구제.제02절 가처분>

[예상][7.02-1]항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부에 관한 학설 및 판례의 입장

《【문제7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 개발행위허가 취소처분을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 가처분 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음1) 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설의 대립과 대법원 판례의 입장을 기술하라.》

<문제7.2의 물음1> 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부에 관한 학설 및 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위허가 취소처분에 대한 취소소송 중 집행정지 신청이 기각되자 가처분을 통한 권리보호를 시도하고, 乙은 거부처분 취소소송 중 수익적 지위를 임시로 확보하기 위한 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <항고소송에서 행정소송법상 집행정지 제도 외에 민사소송법상 가처분 규정의 준용이 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고소송에서 가처분 준용 가능성에 관한 학설과 판례의 입장을 기술한다.

II. 가처분의 의의 및 행정소송 가구제와의 관계

1. 가처분의 개념

- 가처분이란 금전채권 이외의 권리 또는 법률관계에 관한 확정판결의 강제집행을 보전하기 위하여 임시로 내려지는 명령을 말한다. 민사소송법상 가처분은 현상의 변경을 금지하는 다툼의 대상에 관한 가처분과 임시의 지위를 설정하는 임시처분으로 구분된다.

2. 집행정지와와의 차이

- 행정소송법 제23조가 규정하는 집행정지는 기존 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 정지시키는 소극적 가구제 수단이다. 반면 민사소송법상의 임시처분적 가처분은 신청인에게 임시의 지위를 부여하거나 적극적인 행위를 명하는 적극적 가구제 수단의 성격을 갖는다.

III. 가처분 규정 준용 여부에 관한 학설 및 판례

1. 학설의 대립

(1) 긍정설

- 행정소송법 제8조 제2항에 의해 민사소송법 규정이 준용될 수 있고, 집행정지만으로는 거부처분이나 부작위와 같은 사안에서 실효적인 권리구제가 불가능하므로 가처분이 인정되어야 한다는 견해이다. 헌법상 재판받을 권리와 실질적 법치주의의 구현을 근거로 한다.

(2) 부정설

- 행정소송법 제23조가 집행정지 제도를 별도로 두고 있는 것은 항고소송에서 가처분을 배제하려는 입법 취지로 해석한다. 또한, 가처분을 인정할 경우 행정권의 1차적 판단권을 침해하고 권력분립 원칙에 반할 우려가 있다는 점을 근거로 한다.

(3) 절충설

- 원칙적으로 부정하되, 집행정지만으로는 도저히 구제할 수 없는 예외적인 경우에 한하여 보충적으로 가처분을 허용하자는 견해이다.

2. 대법원 판례의 입장

(1) 항고소송에서의 부정

- 대법원은 항고소송인 취소소송이나 무효확인소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 일관되게 유지하고 있다. 판례는 행정처분의 집행정지 사건에서 행정소송법 제23조의 집행정지 규정은 민사소송법상의 가처분에 대한 특칙이므로, 항고소송에서는 집행정지만이 허용될 뿐 가처분은 허용되지 않는다고 판시한다.

(2) 거부처분에 대한 판단

- 특히 거부처분에 대한 취소소송에서도 대법원은 가처분을 부정한다. 거부처분 취소소송에서 가처분을 통해 임시 지위를 설정하는 것은 행정청에 특정 행위를 강제하는 결과를 초래하여 사법권의 한계를 넘어서는 것으로 본다.

(3) 당사자소송과의 비교

- 다만 대법원은 국가를 상대로 한 당사자소송에서는 행정소송법 제44조 제1항이 집행정지 규정을 준용하지 않고 있으므로, 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있다고 보아 항고소송과 결론을 달리하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 임시처분 신청에 대한 검토

- 甲이 신청하고자 하는 가처분은 취소소송 과정에서 공사 중지를 막아달라는 취지의 지위 설정이다. 대법원 판례의 법리에 따르면, 취소소송에서는 행정소송법 제23조의 집행정지 규정이 우선 적용되며 민사소송법상의 가처분은 준용되지 않는다. 따라서 甲의 가처분 신청은 법원에 의해 부적법한 것으로 판단될 가능성이 높다.

2. 乙의 가처분 신청에 대한 검토

- 乙은 거부처분 취소소송에서 수익적 지위 설정을 구하는 가처분을 신청하였다. 거부처분의 경우 집행정지를 하더라도 처분 전의 상태인 신청 시로 돌아갈 뿐이어서 실효성이 없다는 비판이 있으나, 판례는 여전히 권력분립과 특칙 우선의 원칙을 이유로 항고소송에서의 가처분을 부정하므로 乙의 신청 역시 받아들여지기 어렵다.

V. 결론

- 현행법 체계와 대법원 판례의 확립된 태도에 의하면 항고소송에서는 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다. 이는 행정소송법 제23조가 집행정지를 특칙으로 규정하고 있기 때문이며, 사법권이 행정권의 영역에 적극적으로 개입하여 임시 지위를 설정하는 것을 경계하는 취지이다. 따라서 사안의 甲과 乙의 가처분 신청은 모두 허용되지 않는다는 것이 판례의 관점이다. 이러한 법리는 행정소송에서의 가구제 수단이 소극적인 집행정지에 국한되어 있다는 한계를 보여주며, 향후 입법적 개선을 통해 임시처분 제도의 도입 필요성이 논의되는 배경이 된다.

<제07장 취소소송의 가구제.제02절 가처분>

[예상][7.02-2]거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

《【문제7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 개발행위허가 취소처분을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 가처분 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음2) 특히 거부처분에 대한 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상 집행정지 제도로는 목적을 달성할 수 없는 이유와 가처분의 필요성 및 허용 여부에 대해 논하라.》

<문제7.2의 물음2> 거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 수익적 처분을 신청하였으나 거부처분을 받아 이에 대한 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전 임시로 수익적 지위를 확보하기 위한 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <거부처분 취소소송에서 현행 행정소송법상 집행정지 제도의 한계와 가처분에 의한 임시적 권리구제의 필요성 및 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분에 대한 취소소송에서 가처분 제도의 적용 가능성과 그 인정 여부를 검토한다.

II. 거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 흠결

1. 집행정지의 소극적 성격

- 집행정지는 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 멈추는 소극적인 구제 수단이다. 이는 처분이 발해지기 전의 상태로 되돌려 놓는 것에 불과하며, 신청인에게 새로운 법적 지위를 부여하거나 적극적인 이행을 명하는 기능은 없다.

2. 거부처분 집행정지의 무용성

(1) 신청 시 상태로의 복귀

- 거부처분의 효력을 정지시키면 처분이 없었던 것과 같은 상태가 된다. 즉, 乙이 수익적 처분을 신청한 직후의 상태로 돌아갈 뿐이며, 행정청 B가 乙에게 수익적 처분을 내린 것과 같은 효과는 발생하지 않는다.

(2) 재처분의무의 불준용

- 행정소송법 제23조는 본안판결의 기속력 중 재처분의무(제30조 제2항)를 준용하고 있지 않다. 따라서 거부처분의 집행이 정지된다고 하더라도 행정청에게 임시로라도 수익적 처분을 하도록 강제할 법적 근거가 없다. 결국 乙은 판결 확정 전까지 아무런 실질적 이득을 얻지 못하게 된다.

III. 항고소송에서 민사소송법상 가처분의 필요성 및 허용 여부

1. 가처분의 필요성

- 거부처분이나 부작위와 같이 집행정지만으로는 권리구제의 실효성을 확보할 수 없는 영역에서 적극적 가구제 수단인 가처분의 필요성이 제기된다. 乙의 경우처럼 판결 확정 전까지 임시로 수익적 지위를 설정받아야 할 긴급한 필요가 있는 경우 가처분은 유일한 대안이 될 수 있다.

2. 학설 및 판례의 입장

(1) 학설의 대립

- 긍정설은 헌법상 재판받을 권리와 국민의 실효적 권리구제를 위해 행정소송법 제8조 제2항에 따라 가처분을 인정해야 한다고 주장한다. 반면 부정설은 행정소송법이 집행정지만을 명시한 것은 가처분을 배제하려는 취지이며, 가처분을 허용할 경우 사법부가 행정권의 영역을 침해하여 권력분립 원칙에 반한다고 본다.

(2) 대법원 판례의 입장

- 판례는 항고소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 명확히 하고 있다. 대법원은 행정소송법 제23조가 집행정지라는 특칙을 두고 있으므로 민사소송법상의 가처분이 개입할 여지가 없다고 판시한다. 특히 거부처분에 대한 가처분은 행정청의 1차적 판단권을 침해하는 것으로 보아 허용하지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 집행정지 신청 시의 한계

- 乙이 거부처분 취소소송에서 집행정지를 신청하여 승인받더라도, 이는 행정청 B가 乙의 신청을 거부했다는 사실을 잠정적으로 지우는 것에 불과하다. 乙이 원했던 수익적 처분의 효과(예 : 영업 허가 등)는 발생하지 않으므로, 乙은 본안 판결이 확정될 때까지 경제적 손실 등 위험에 노출된다.

2. 乙의 가처분 신청에 대한 판단

- 판례의 입장에 따를 때, 乙이 제기한 가처분 신청은 항고소송에서의 가처분 부정 법리에 따라 부적법 각하될 운명에 있다. 乙이 주장하는 적극적 가구제의 필요성은 인정되나, 현행법 해석상 사법부가 행정청을 대신하여 임시 지위를 창설해 주는 것은 권력분립의 한계를 넘는 것으로 간주되기 때문이다.

V. 결론

- 거부처분 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상의 집행정지는 단순히 거부의 상태를 정지시킬 뿐 신청인에게 적극적인 권리 상태를 형성해 주지 못하므로 목적 달성에 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 적극적 가구제인 가처분이 필요하나, 대법원 판례는 권력분립과 행정소송법의 특칙 우선 이유를 이유로 항고소송에서의 가처분 준용을 부정하고 있다. 이러한 논의는 현행 가구제 제도의 불비로 인해 발생하는 거부처분 상대방의 권리구제 공백을 확인시켜 주며, 장차 행정소송법 개정 시 임시처분 제도의 명문화가 필요함을 시사한다.

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제02절 소의 변경>

[예상][8.02-1]취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

《【문제8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 개발행위허가 거부처분을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 취소소송을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 부작위위법확인소송으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 6개월 처분을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 영업정지 2개월로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음1) 甲이 현재 진행 중인 취소소송을 부작위위법확인소송으로 변경하고자 할 때, 행정소송법 제21조에 따른 소의 종류의 변경의 요건과 허용 범위에 대하여 설명하라.》

<문제8.2의 물음1> 취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위허가 거부처분 취소소송이 계속 중인 상태에서 부작위위법확인소송으로 소송의 종류를 변경하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법 제21조에 따른 소의 종류 변경이 인정되기 위한 요건과 취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 변경이 허용되는 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소의 종류 변경 제도의 의의와 요건 및 그 허용 범위에 대해 설명한다.

II. 소의 종류의 변경의 의의 및 성질

1. 의의

- 소의 종류의 변경이란 원고가 제기한 소송을 다른 종류의 항고소송이나 당사자소송으로 변경하는 것을 말한다. 이는 소의 제기 후에 발생한 사정변경에 대응하거나, 당초 소 제기가 잘못된 경우 원고의 권리구제를 도모하고 소송경제를 실현하기 위한 제도이다.

2. 법적 성질

- 행정소송법 제21조에 의한 소의 변경은 구소(취소소송)를 취하하고 신소(부작위위법확인소송)를 제기하는 성격을 동시에 가진다. 이때 신소는 구소가 제기된 때에 제기된 것으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단하게 되는 소급효의 특징이 있다.

III. 소의 종류의 변경의 요건

1. 소의 계속과 사실심 변론종결 전

- 변경하고자 하는 구소가 법원에 적법하게 계속되어 있어야 하며, 소의 변경 신청은 사실심(제1심 또는 제2심)의 변론종결 전까지 이루어져야 한다. 사안의 甲은 제1심 소송이 계속 중이므로 이 요건을 충족한다.

2. 청구의 기초의 동일성

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없는 범위 내에서 허용된다. 이는 구소와 신소가 동일한 행정작용이나 사실관계에 근거하고 있어 소송자료를 공통적으로 활용할 수 있는 경우를 의미한다. 甲의 경우 개발행위허가 신청에 대한 행정청의 반응(거부 또는 부작위)을 다투는 것이므로 청구의 기초가 동일하다고 볼 수 있다.

3. 신소의 적법성

- 변경되는 신소인 부작위위법확인소송은 그 자체로 소송요건을 갖추고 있어야 한다. 다만 제소기간의 경우 행정소송법 제21조 제4항 및 제14조 제4항에 따라 구소가 제기된 때에 제기된 것으로 간주되므로 구소의 제소기간 내 제기 여부가 중요하다.

4. 법원의 재량과 피고의 의견 청취

- 법원은 소의 변경이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 허가한다. 이때 법원은 피고의 의견을 들어야 한다. 피고가 소 변경에 반대하더라도 청구의 기초가 동일하고 변경의 필요성이 인정된다면 법원은 이를 허가할 수 있다.

IV. 소의 종류의 변경의 허용 범위와 사안의 특수성

1. 변경의 방향

- 행정소송법 제21조는 항고소송 상호 간(취소소송 ↔ 무효확인소송 ↔ 부작위위법확인소송)의 변경뿐만 아니라 항고소송과 당사자소송 간의 변경도 허용한다.

2. 거부처분 취소소송과 부작위위법확인소송의 관계

(1) 처분의 존재 여부

- 사안에서 행정청 A는 이미 거부처분을 내린 상태이다. 부작위위법확인소송은 행정청이 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우에 제기하는 소송이다.

(2) 소 변경의 허용 범위에 관한 고찰

- 거부처분이 엄연히 존재하는 상황에서 이를 부작위로 보아 부작위위법확인소송으로 변경하는 것은 원칙적으로 대상적격의 흠결 문제를 발생시킬 수 있다. 판례에 따르면 거부처분이 있는 경우에는 부작위위법확인소송을 제기할 수 없다. 따라서 甲이 소를 변경하려 할 때, 법원은 단순히 소 변경의 절차적 요건뿐만 아니라 변경된 신소가 부작위라는 요건을 실질적으로 충족하는지를 심사하게 된다. 만약 거부처분의 통지가 도달하지 않았거나 행정청의 반응이 부작위로 해석될 여지가 있다면 소 변경이 유효할 것이나, 명확한 거부처분이 있는 상황에서의 변경은 부적법한 신소로 귀결될 위험이 있다.

V. 결론

- 甲이 제기한 취소소송을 부작위위법확인소송으로 변경하는 것은 행정소송법 제21조에 따라 사실심 변론종결 전까지 청구의 기초가 동일하다면 신청할 수 있다. 소 변경이 허가되면 신소는 구소 제기 시에 제기된 것으로 간주되는 유리함이 있다. 다만, 사안에서 행정청 A의 명시적인 거부처분이 존재하는 상황이라면 변경된 부작위위법확인소송은 대상적격 흠결로 각하될 가능성이 높으므로, 甲은 법률 전문가의 조언에도 불구하고 실질적인 소송의 실익을 신중히 검토해야 한다. 이러한 법리는 원고의 주관적 권리구제를 넓게 보장하면서도, 소송 대상의 성질에 따른 소송 종류의 적정성을 유지하려는 행정소송법의 태도를 반영한다.

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제02절 소의 변경>
[예상][8.02-2]처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

《【문제8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 개발행위허가 거부처분을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 취소소송을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 부작위위법확인소송으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 6개월 처분을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 영업정지 2개월로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음2) 乙의 사례와 같이 소송 계속 중 행정청이 처분을 변경한 경우, 乙이 기존의 소송을 유지하면서 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼기 위해 활용할 수 있는 처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 그 신청 기한에 대하여 기술하라.》

<문제8.2의 물음2> 처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 영업정지처분 취소소송을 제기하여 소송이 계속 중인 상태에서 행정청이 당초 처분을 감경하는 변경처분을 하자 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼으려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 처분변경으로 인한 소의 변경이 인정되기 위한 요건과 그 신청기간>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분변경으로 인한 소의 변경 제도의 의의와 요건 및 신청 기한에 대해 기술한다.

II. 처분변경으로 인한 소의 변경의 의의 및 성질

1. 의의

- 처분변경으로 인한 소의 변경이란 피고인 행정청이 소송의 대상인 처분을 소송 계속 중에 변경한 경우, 원고가 변경된 새로운 처분에 맞추어 소송의 대상을 바꾸거나 청구 내용을 변경하는 제도를 의미한다. 이는 행정청의 처분 변경으로 인해 기존 소송의 실익이 소멸하는 것을 방지하고 원고의 권리구제를 도모하기 위한 것이다.

2. 법적 성질

- 행정소송법 제21조에 의한 소의 종류의 변경과 달리, 제22조는 소송의 대상이 된 처분이 사후적으로 변경되었다는 특수한 사정을 고려한 제도이다. 소 변경이 허가되면 구소는 취하된 것으로 보고 신소가 제기된 것으로 간주하며, 제소기간의 준수 여부는 구소가 제기된 때를 기준으로 판단하는 소급효가 인정된다.

III. 처분변경으로 인한 소의 변경 요건

1. 항고소송의 계속과 처분의 변경

- 취소소송 등 항고소송이 법원에 적법하게 계속 중이어야 한다. 또한 소송의 대상이 된 당초 처분을 행정청이 소송 계속 중에 변경하였어야 한다. 사안의 경우 영업정지 6개월 처분이 2개월로 감경된 것은 처분의 실질적 내용이 바뀐 것이므로 처분의 변경에 해당한다.

2. 사실심 변론종결 전일 것

- 소의 변경 신청은 사실심(제1심 또는 제2심)의 변론종결 전까지만 가능하다. 상고심에서는 새로운 처분을 대상으로 하는 소의 변경이 허용되지 않는다.

3. 처분의 변경이 소송 대상에 영향을 미칠 것

- 행정청의 처분 변경으로 인하여 구소의 청구취지나 청구원인을 변경할 필요가 있어야 한다. 사안에서 乙은 영업정지 6개월의 취소를 구하고 있었으므로, 감경된 2개월 처분의 취소를 구하기 위해서는 소의 변경이 필수적이다.

4. 법원의 허가 결정

- 법원은 원고의 신청이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 소의 변경을 허가한다. 이때 법원은 피고 행정청의 의견을 들어야 한다.

IV. 신청 기한

1. 원칙적 기한

- 행정소송법 제22조 제2항에 따라 처분변경으로 인한 소의 변경 신청은 처분의 변경이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 하여야 한다.

2. 기간의 성격

- 이 60일의 기간은 불변기간이다. 따라서 원고가 처분이 변경되었음을 알고도 60일이 경과한 후에 신청한다면 법원은 이를 부적법한 신청으로 보아 각하하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 소 변경 가능성

- 사안에서 행정청 B가 소송 중에 영업정지 기간을 감경한 것은 乙에게 유리한 변경이지만, 乙이 2개월의 정지 처분 자체도 불복하고자 한다면 행정소송법 제22조에 따라 소를 변경해야 한다. 乙은 영업정지 2개월 처분이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 법원에 소 변경 신청서를 제출해야 한다.

2. 감경처분의 특수성과 판례의 태도

- 대법원 판례에 따르면, 사안과 같은 감경처분의 경우 변경된 내용의 당초 처분이 소송의 대상이 된다. 즉, 영업정지 6개월 중 4개월이 취소되고 남은 2개월 분의 영업정지가 소송의 대상이 되는 것이다. 乙은 소 변경을 통해 청구취지를 영업정지 6개월 처분 중 취소되지 않고 남은 2개월 처분을 취소한다는 형태로 수정하여 소송을 유지할 수 있다.

VI. 결론

- 乙은 행정청 B의 처분 변경에 대응하여 행정소송법 제22조에 따른 처분변경으로 인한 소의 변경을 신청할 수 있다. 이를 위해서는 사실심 변론종결 전까지 처분 변경을 안 날로부터 60일 이내에 신청서를 제출하여야 한다. 법원의 허가를 얻으면 乙은 기존 소송 절차에서 현출된 자료들을 활용하면서 변경된 영업정지 2개월 처분의 위법성을 계속해서 다룰 수 있게 된다. 이러한 법리는 소송 계속 중 행정청의 처분 변경으로 인해 원고가 불필요하게 새로운 소송을 처음부터 다시 제기해야 하는 번거로움을 덜어주고, 분쟁의 일회적 해결을 가능하게 하는 중요한 기능을 수행한다.

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[예상][9.04-1]무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

《【문제9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 사정판결을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음1) 무효확인소송에서 행정소송법 제28조의 사정판결 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설 및 대법원 판례의 입장을 서술하고, 사안의 수용재결이 무효인 경우 법원이 사정판결을 내릴 수 있는지 답하라.》

<문제9.4의 물음1> 무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A의 수용재결에 대하여 甲이 중대한 하자가 있다고 주장하고, 법원은 해당 처분이 무효라고 판단하였으나 A는 공공복리에 중대한 지장이 초래된다는 이유로 사정판결을 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 취소소송의 특유한 제도인 사정판결 규정의 준용 가능 여부와 무효인 처분에 대한 사정판결의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 수용재결 무효에 대한 사정판결 가능 여부를 검토한다.

II. 사정판결의 의의 및 근거

1. 의의

- 사정판결이란 원고의 청구가 이유 있다고 인정되어 처분 등이 위법함에도 불구하고, 그 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에 법원이 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. 이는 사법 국가 원칙에 대한 예외로서 공익과 사익의 조화를 도모하기 위한 제도이다.

2. 법적 근거

- 행정소송법 제28조 제1항은 취소소송에 관하여 사정판결을 명시하고 있다. 무효확인소송의 경우에는 동법 제38조 제1항에서 제28조를 준용하는 규정을 두고 있지 않아, 그 허용 여부가 해석상 논란이 된다.

III. 무효확인소송에서 사정판결 준용 여부에 관한 논의

1. 학설의 대립

(1) 준용 긍정설

- 무효인 처분이라 하더라도 이를 무효로 확정할 경우 공공복리에 중대한 지장을 초래할 수 있는 사정은 취소소송과 다를 바 없으므로, 행정소송법 제8조 제2항에 의해 민사소송법이나 일반 원칙을 적용하거나 유추 준용하여 사정판결을 인정해야 한다는 견해이다.

(2) 준용 부정설(다수설)

- 행정소송법 제38조 제1항이 준용 규정에서 제28조를 제외하고 있는 것은 입법자의 결단으로 보아야 한다. 무효인 처분은 처음부터 아무런 효력이 없는 것으로서 외형상 존재함으로 인한 공익적 사정보다 법치주의의 확립이 우선되어야 한다는 점을 근거로 한다.

2. 대법원 판례의 입장

- 대법원은 일관되게 무효확인소송에서 사정판결을 부정하고 있다. 판례는 행정소송법 제38조 제1항이 제28조를 준용하고 있지 아니함에 비추어 볼 때, 행정처분이 당연무효인 경우에는 사정판결을 할 수 없다고 명시적으로 판시하였다. 즉, 하자가 중대한 하자가 명백하여 당연무효인 처분은 사정판결의 대상이 될 수 없다는 것이 확립된 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 수용재결의 성격과 하자의 정도

- 사안에서 법원은 수용재결에 중대한 하자가 있어 당연무효라고 판단하였다. 당연무효인 처분은 법적 효력이 발생하지 않는 것이 원칙이므로, 그 처분에 기하여 진행된 공사 등의 외형적 결과가 존재하더라도 원칙적으로 법적 보호를 받기 어렵다.

2. 사정판결의 가능성 검토

- 행정청 A는 공사 진행률 90%, 예산 낭비, 교통 혼란 등의 공익적 사유를 들어 사정판결을 주장한다. 그러나 대법원 판례의 견해에 의하면 무효확인소송에서는 행정소송법 제28조가 준용되지 않으므로 법원은 사정판결을 내릴 수 없다. 하자가 무효 사유에 해당하는 이상, 설령 공익상 중대한 지장이 예상된다 하더라도 법원은 당해 수용재결이 무효임을 확인하는 판결을 내려야 한다.

V. 결론

- 무효확인소송에서 사정판결의 인정 여부에 대하여 학설은 대립하나, 대법원 판례는 행정소송법상 준용 규정의 부재를 근거로 이를 엄격히 부정하고 있다. 사안의 경우 수용재결에 중대한 하자가 있어 무효로 판단된 이상, 행정청 A가 주장하는 공공복리상의 사유가 존재하더라도 법원은 사정판결을 내릴 수 없으며 甲의 청구를 인용하여 무효를 확인하여야 한다. 이러한 법리는 무효인 행정행위에 대해서는 공익을 이유로 한 예외를 허용하지 않으므로써 국민의 기본권을 철저히 보호하고 행정의 적법성을 담보하려는 사법부의 의지를 반영한다. 다만, 이로 인해 발생하는 현실적인 공익 침해 문제는 수용재결의 재시행이나 손실보상 등 별도의 절차를 통해 해결되어야 할 과제로 남는다.

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[예상][9.04-2]무효확인판결의 제3자효와 기속력의 의미 및 재처분의무의 인정 여부

《【문제9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 사정판결을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음2) 무효확인판결이 확정되었을 때 발생하는 판결의 효력 중 제3자효와 기속력의 의미를 설명하고, 특히 기속력의 내용 중 행정청의 재처분의무가 무효확인소송에서도 인정되는지 기술하라.》

<문제9.4의 물음2> 무효확인판결의 제3자효와 기속력의 의미 및 재처분의무의 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 수용재결 무효확인소송에서 승소할 경우 판결의 효력이 처분청 A 외의 다른 국가기관에도 미치는지와 행정청의 후속 의무에 대해 궁금해하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인판결의 효력 중 제3자효와 기속력의 의미 및 무효확인소송에서도 기속력에 따른 행정청의 재처분의무가 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인판결의 제3자효와 기속력의 내용 및 무효확인소송에서의 재처분의무 인정 여부를 기술한다.

II. 무효확인판결의 제3자효(대세효)

1. 의미

- 제3자효란 처분 등을 무효로 하는 판결의 효력이 소송 당사자인 원고와 피고 행정청뿐만 아니라 제3자에 대하여도 미치는 효력을 의미한다. 행정소송법 제38조 제1항은 제12조 제3항(제3자효)을 무효확인소송에 준용하고 있다.

2. 내용 및 취지

- 제3자효가 인정됨에 따라 무효확인판결이 확정되면 누구든지 해당 처분이 무효임을 전제로 행동해야 하며, 다른 국가기관이나 법원도 그 처분의 무효를 전제로 판단해야 한다. 이는 행정법관계의 확실적 확정을 기하고 판결의 실효성을 높이기 위한 것이다. 甲의 경우 승소 판결이 확정되면 처분청 A 뿐만 아니라 다른 모든 국가기관에 대해서도 해당 수용재결이 무효임을 주장할 수 있다.

III. 무효확인판결의 기속력

1. 의미

- 기속력이란 처분 등을 무효로 하는 판결이 확정된 경우 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동해야 하는 구속력을 말한다. 행정소송법 제38조 제1항은 제30조(기속력)를 준용하고 있다.

2. 기속력의 내용

(1) 반복금지의무

- 행정청은 판결에서 무효로 확인된 처분과 동일한 사유에 근거하여 동일한 내용의 처분을 반복해서는 안 되는 의무를 진다.

(2) 원상회복의무(결과제거의무)

- 행정청은 무효인 처분에 의하여 초래된 위법한 상태를 제거하고 처분 전의 상태로 되돌려 놓아야 할 의무를 진다. 사안에서 수용재결이 무효로 확인되면 행정청 A는 원칙적으로 토지 소유권을 甲에게 반환하는 등 위법한 결과를 제거해야 한다.

IV. 무효확인소송에서의 재처분의무 인정 여부

1. 문제의 소재

- 행정소송법 제30조 제2항은 신청에 따른 처분이 절차상 하자 등을 이유로 취소된 경우 행정청에 재처분의무를 부과하고 있다. 무효확인소송의 준용 규정인 제38조 제1항이 제30조 제2항을 명시적으로 포함하고 있는지, 그리고 거부처분이 무효인 경우에도 재처분의무가 당연히 인정되는지가 쟁점이다.

2. 법적 근거의 검토

(1) 행정소송법 개정 전후의 상황

- 과거 행정소송법 제38조 제1항은 제30조 제2항(재처분의무)을 준용 규정에서 누락하고 있었다. 이로 인해 거부처분 무효확인판결이 확정되더라도 행정청에 재처분의무가 있는지에 대해 학설상의 다툼이 있었다.

(2) 현행법의 태도

- 2014년 행정소송법 개정을 통해 제38조 제1항에 제30조 제2항이 명시적으로 포함되었다. 따라서 현재는 거부처분이 무효로 확인된 경우에도 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 처분을 해야 할 법적 의무를 진다.

3. 수용재결 사안에서의 적용

- 사안의 수용재결은 행정청이 일방적으로 내리는 형성적 행위이지만, 넓게 보면 도로 공사라는 공익사업을 위한 절차이다. 수용재결이 무효로 확정되면 행정청 A는 기속력에 따라 위법 사유를 보완하여 적법한 절차를 다시 밟거나(재처분의무의 준하는 행위), 무효인 재결에 기초한 점유를 해소해야 한다.

V. 사안의 적용

1. 제3자효의 적용

- 甲이 무효확인소송에서 승소하면 그 판결의 효력은 제3자효(대세효)에 의해 처분청 A 외에 토지 수용과 관련된 다른 행정기관이나 등기소 등 모든 국가기관에 미친다. 따라서 甲은 판결문을 근거로 수용재결의 효력이 없음을 누구에게나 주장할 수 있다.

2. 기속력과 재처분의무의 발동

- 판결이 확정되면 행정청 A는 기속력을 받는다. 사안의 수용재결이 무효로 확인된 이상 행정청 A는 해당 재결이 유효함을 전제로 공사를 계속하거나 토지를 점유할 수 없다. 또한 개정 행정소송법에 따라 재처분의무 규정이 준용되므로, 행정청 A가 공사를 계속 진행하고자 한다면 판결에서 지적된 중대·명백한 하자를 시정한 후 적법하게 다시 수용 절차를 밟아야 한다.

Ⅵ. 결론

- 무효확인판결은 취소판결과 마찬가지로 제3자효와 기속력이 인정된다. 따라서 甲은 판결의 효력을 다른 국가기관에도 주장할 수 있으며, 피고 행정청 A는 판결의 취지에 따라 행동해야 할 의무를 진다. 특히 현행 행정소송법은 무효확인소송에서도 재처분의무를 명시적으로 인정하고 있으므로, 행정청 A는 무효인 수용재결을 방지해서는 안 되며 판결에 따른 적법한 후속 조치를 취해야 한다. 이러한 법리는 행정처분이 무효인 경우 판결의 실효성을 확보하여 국민의 권익을 구체적으로 구제하고, 행정의 적법성을 회복하도록 강제하는 데 그 의의가 있다.

《【문제9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 토양환경보전법 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 증대하고 명백한 하자가 있어 당연히무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음1) 무효확인소송에서 행정소송법 제23조의 집행정지 규정이 준용되는지 여부를 밝히고, 무효확인소송에서의 집행정지 요건 중 회복하기 어려운 손해의 의미에 대하여 취소소송과 비교하여 서술하라.》

<문제9.6의 물음1> 무효확인소송에서 집행정지 규정의 준용 여부와 회복하기 어려운 손해의 의미

I 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A가 甲의 공장에 대하여 사용중지 명령을 하였고, 甲은 해당 처분의 무효확인소송을 제기하면서 처분의 효력을 정지시키기 위한 가구제 수단을 모색하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서도 취소소송과 마찬가지로 행정소송법상 집행정지 규정이 준용되는지 여부와 집행정지 요건인 회복하기 어려운 손해의 의미>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서의 집행정지 인정 여부와 회복하기 어려운 손해의 판단 기준을 취소소송과 비교하여 서술한다.

II 무효확인소송에서 집행정지의 준용 여부

1. 의의

- 집행정지는 처분의 집행이나 효력의 발생을 잠정적으로 멈추어 원고의 권리를 보호하는 가구제 수단이다. 무효확인소송은 처분의 효력이 존재하지 않음을 전제로 하지만, 외형상 처분이 존재하는 이상 그로 인한 집행을 위험을 차단할 필요가 있다.

2. 법적 근거 및 견해의 대립

(1) 긍정설 및 행정소송법의 태도

- 현행 행정소송법 제38조 제1항은 제23조를 명시적으로 준용하고 있다. 무효인 처분이라도 처분의 외형이 남아 있어 집행력이 행사될 가능성이 있으므로, 국민의 권익 보호를 위해 집행정지를 인정해야 한다는 취지이다.

(2) 부정설

- 무효인 처분은 처음부터 아무런 효력이 없으므로 정지할 효력 자체가 존재하지 않는다는 논리이다. 즉, 관념적으로 존재하지 않는 효력을 정지한다는 것은 논리적으로 모순이라는 견해이다.

(3) 판례의 입장

- 대법원은 행정소송법의 준용 규정에 따라 무효확인소송에서도 집행정지가 허용된다는 점을 명확히 하고 있다. 다만, 무효확인소송에서의 집행정지는 취소소송과 비교하여 그 요건인 손해의 성격에 대하여 다소 엄격하게 해석될 여지가 있다.

III 집행정지 요건 중 회복하기 어려운 손해의 의미

1. 취소소송에서의 의미

(1) 개념의 확장

- 과거에는 금전 보상이 불가능한 손해만을 의미했으나, 현대적 판례는 금전 보상이 가능하더라도 사회통념상 원고가 참고 견디기 어렵거나 원상회복이 현저히 곤란한 경우를 포함하는 광의의 개념으로 해석한다.

(2) 구체적 판단 기준

- 사업의 중단으로 인한 막대한 경제적 손실, 기업 이미지의 실추, 파산의 위기 등 원고의 법적 지위에 심대한 타격을 줄 우려가 있는 경우 회복하기 어려운 손해로 인정된다.

2. 무효확인소송에서의 의미 및 비교

(1) 논리적 차이

- 무효인 처분은 처분 그 자체로 효력이 없으므로, 원고는 처분을 무시하고 행동할 수도 있다. 그러나 사실상의 강제집행이 예정되어 있거나 외형상 처분으로 인해 법률관계가 극도로 불안정해지는 경우 가구제의 필요성이 발생한다.

(2) 판례의 독특한 입장

- 대법원은 무효확인청구의 소에는 처분의 효력 정지를 구할 법률상 이익이 있어야 한다고 판시하면서, 만약 처분의 효력을 정지하지 않더라도 처분이 당연히무효임을 주장하여 민사소송 등 다른 방법으로 손해를 충분히 구제받을 수 있다면 집행정지의 필요성을 부정적으로 보는 경향이 있다.

(3) 비교 요약

- 취소소송에서는 처분의 공정력 때문에 일단 따라야 하는 의무가 발생하므로 손해의 범위를 넓게 보지만, 무효확인소송에서는 처분에 공정력이 없으므로 오직 실행력이 행사되어 실제로 권리가 침해될 긴급한 사정이 있는 경우에 한하여 보다 엄격하게 해석되는 측면이 있다.

IV 사안의 적용

1. 집행정지의 준용 및 신청

- 사안에서 행정청 A의 사용중지 명령은 무효확인소송의 대상이며, 행정소송법 제38조 제1항에 따라 제23조 집행정지 규정이 준용된다. 따라서 甲은 공장 가동 중단이라는 위기에 대응하기 위해 집행정지를 신청할 수 있다.

2. 회복하기 어려운 손해의 존부

- 甲은 공장 가동 중단 시 거래처와의 계약 위반 및 막대한 손해 발생을 주장하고 있다. 이는 단순히 금전으로 보상될 수 있는 범위를 넘어 기업의 존립을 위협하거나 거래 질서를 파괴할 우려가 있는 경우에 해당한다. 비록 무효확인소송에서 손해의 요건을 비교적 엄격히 보더라도, 사용중지 명령이라는 직접적인 강제력이 수반되는 처분의 경우 회복하기 어려운 손해 및 긴급한 필요가 인정될 가능성이 높다.

V. 결론

- 무효확인소송에서도 행정소송법의 준용 규정에 따라 집행정지 제도가 인정된다. 이는 처분의 무효 여부와 상관없이 사실상의 집행력을 차단하여 국민을 보호하기 위함이다. 집행정지의 요건인 회복하기 어려운 손해는 취소소송과 마찬가지로 원상회복이나 금전 보상이 극도로 곤란한 경우를 의미하나, 무효인 처분은 원칙적으로 효력이 없다는 특수성 때문에 실제 집행 가능성이 구체적으로 증명되어야 한다는 점이 취소소송과의 실무적 차이점이다. 사안의 甲은 공장 중단으로 인한 파괴적 손해를 소명함으로써 가구제를 받을 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 법리는 무효인 행정행위의 외형이 가져오는 법적 혼란을 잠정적으로 해소하고, 본안 판결 전까지 신청인의 권익을 실효적으로 보전하는 데 기여한다.

<제09장 무효등 확인소송.제06절 가구제>

[예상][9.06-2]무효확인소송에서 가처분의 준용 여부와 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

《【문제9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 토양환경보전법 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음2) 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 관한 판례의 입장을 기술하고, 乙이 신청하려는 예방적 금지 성격의 가처분이 허용되는지 답하라.》

<문제9.6의 물음2> 무효확인소송에서 가처분의 준용 여부와 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

I 문제의 제기

- 사안에서 甲은 사용중지 명령처분에 대한 무효확인소송을 제기하면서 처분의 효력을 정지하기 위한 가구제 수단을 모색하고, 乙은 행정청 A의 장래 처분을 금지하기 위한 예방적 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 가능 여부와 행정청의 장래 처분을 사전에 금지하는 예방적 금지 가처분의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 가처분 준용에 관한 판례의 입장과 예방적 금지 가처분의 인정 여부에 대해 답한다.

II 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부

1. 판례의 일반적인 태도

(1) 항고소송에서의 부정

- 대법원은 취소소송이나 무효확인소송과 같은 항고소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 확고히 하고 있다. 판례는 행정소송법 제23조에서 규정하고 있는 집행정지 제도가 민사소송법상 가처분에 대한 특칙이라고 본다.

(2) 부정의 근거

- 항고소송은 행정청의 처분을 대상으로 하는 소송이므로, 사법부가 가처분을 통해 행정청의 행위를 미리 금지하거나 임시 지위를 설정하는 것은 권력분립의 원칙에 반하고 행정권의 1차적 판단권을 침해할 우려가 있다는 점을 주된 근거로 삼는다.

2. 당사자소송과의 비교

- 대법원은 국가를 상대로 하는 당사자소송에서는 행정소송법 제44조 제1항이 집행정지 규정을 준용하지 않고 있다는 점을 근거로 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있다고 판시하여 항고소송과 구분하고 있다. 그러나 사안의 乙이 제기하는 소송은 항고소송인 무효확인소송이므로 위 부정설의 법리가 적용된다.

III 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

1. 예방적 금지소송과 가처분

- 예방적 금지소송이란 행정청이 특정한 처분을 하지 못하도록 미리 구하는 소송이다. 乙이 신청하려는 가처분은 본안소송으로서 예방적 금지소송이 인정됨을 전제로 그 가구제 수단으로서 기능을 한다.

2. 판례의 입장

(1) 본안소송의 부적법성

- 대법원은 예방적 금지소송을 현행 행정소송법상 허용되지 않는 무명항고소송으로 본다. 판례는 행정청이 장래에 내릴 처분을 미리 법원이 금지하는 것은 행정권에 대한 사법권의 지나친 간섭이라고 판단하여 이를 부적법 각하한다.

(2) 가처분의 불허

- 본안소송인 예방적 금지소송 자체가 허용되지 않으므로, 그에 부수하는 가구제 수단으로서의 예방적 금지 가처분 역시 허용될 수 없다. 판례는 처분의 효력 발생 이후에 집행정지 등을 통해 다루는 것 외에, 장래의 처분을 미리 막는 가처분 형식의 권리구제는 인정하지 않는다.

IV 사안의 적용

1. 乙의 무효확인소송과 가처분 신청

- 乙은 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서 가처분을 신청하였다. 그러나 앞서 살펴본 판례의 태도에 따르면 무효확인소송과 같은 항고소송에서는 민사소송법상의 가처분 규정이 준용되지 않는다.

2. 예방적 금지 가처분의 적법성 검토

- 乙이 구하는 향후 내릴지도 모를 완화된 처분을 미리 금지해달라는 신청은 전형적인 예방적 금지 성격의 가처분이다. 우리 판례는 예방적 금지소송 자체를 부정할 뿐만 아니라 항고소송에서의 가처분 준용도 부정하고 있으므로, 乙의 가처분 신청은 법적 근거가 없어 부적법 각하될 것이다. 乙은 실제 처분이 내려진 이후에 그 처분에 대하여 다시 무효확인소송이나 취소소송을 제기하고 집행정지를 신청하는 방식으로 대응해야 한다.

V 결론

- 무효확인소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 대법원은 행정소송법 제23조의 집행정지 규정이 특칙으로서 존재한다는 점과 권력분립 원칙을 근거로 이를 명백히 부정하고 있다. 특히 乙이 신청하고자 하는 예방적 금지 성격의 가처분은 본안소송인 예방적 금지소송의 허용 여부와 직결되는데, 판례는 법문에 명시되지 않은 무명항고소송과 그에 따른 가처분을 일체 인정하지 않는다. 따라서 乙의 가처분 신청은 허용되지 않는다. 이러한 법리는 사법부가 행정청의 처분 권한을 사전에 제약하는 것을 극도로 경계하는 태도를 보여주며, 국민의 가구제 수단이 사후적 수단인 집행정지에 한정되어 있다는 현행 행정쟁송법 체계의 한계를 나타낸다.

<제09장 무효등 확인소송.제07절 청구의 병합과 소의 변경>

[예상][9.07-1]무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

《【문제9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국제 체납을 이유로 압류처분을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음1) 甲이 제기하려는 무효확인청구와 취소청구의 병합이 허용되는지 여부와 관련하여, 두 청구의 관계(주위적·예비적 병합 vs 단순 병합)에 따른 판례의 입장을 기술하라.》

<문제9.7의 물음1> 무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 압류처분의 하자가 무효사유인지 취소사유인지 불확실한 상황에서 무효확인청구와 취소청구를 함께 제기하려 하고, 乙은 무효확인소송 중 취소소송으로 소를 변경하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인청구와 취소청구의 병합 가능 여부와 관련하여 주위적·예비적 병합 및 단순 병합의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인청구와 취소청구의 관계에 따른 병합 형태별 허용 여부를 기술한다.

II. 행정소송상 관련 청구의 병합

1. 병합의 의의 및 근거

- 병합이란 하나의 소송절차에서 여러 개의 청구를 동시에 제기하거나 기존 소송에 다른 청구를 추가하는 것을 말한다. 행정소송법 제10조는 소송의 효율성을 높이고 관련 분쟁을 일회적으로 해결하기 위해 관련 청구소송의 병합을 허용하고 있다.

2. 병합의 형태

(1) 단순 병합

- 여러 개의 청구를 병렬적으로 제기하여 법원이 모두에 대하여 심판을 하도록 하는 형태이다. 청구 상호 간에 양립이 가능한 경우에 주로 활용된다.

(2) 선택적 병합

- 여러 개의 청구 중 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판할 필요가 없는 형태이다. 청구 상호 간에 양립할 수 없는 관계에 있을 때 사용된다.

(3) 주위적·예비적 병합

- 주위적 청구가 기각될 것을 대비하여 예비적 청구를 제기하는 형태이다. 법원은 주위적 청구가 이유 없을 때에만 비로소 예비적 청구를 심리한다.

III. 무효확인청구와 취소청구의 병합에 관한 판례의 입장

1. 주위적·예비적 병합의 허용 여부

(1) 판례의 태도

- 대법원은 동일한 행정처분에 대하여 무효확인청구와 취소청구를 주위적·예비적 병합의 형태로 제기하는 것을 명시적으로 허용하고 있다. 판례는 무효확인소송과 취소소송은 소송물인 처분의 위법성이라는 기초는 동일하지만, 하자의 정도에 따라 양립할 수 없는 관계에 있다고 본다.

(2) 심리 방식

- 법원은 주위적 청구인 무효확인청구를 먼저 심리하여 그 하자가 중대하고 명백하여 무효라고 인정되면 예비적 청구인 취소청구에 대해서는 판단하지 않는다. 만약 하자가 존재하지만 무효 사유에는 이르지 않는 취소 사유에 불과하다고 판단될 때 비로소 예비적 청구를 심리하여 처분을 취소하게 된다.

2. 단순 병합의 허용 여부

(1) 판례의 태도

- 대법원은 동일한 행정처분에 대하여 무효확인청구와 취소청구를 단순 병합의 형태로 제기하는 것은 허용되지 않는다고 판시한다. 판례는 양 청구가 동일한 행정처분을 대상으로 하는 경우, 그 하자가 무효 사유이거나 취소 사유인 것 중 하나일 수밖에 없으므로 양립 불가능한 관계라고 판단하기 때문이다.

(2) 부적법 판정의 근거

- 만약 단순 병합으로 제기되었다 하더라도 법원은 이를 주위적·예비적 병합으로 보아 심리하거나, 병합의 형태를 명확히 하도록 설명권을 행사해야 한다. 무효와 취소를 동시에 선택적으로 청구하는 것은 청구의 취지가 모순되어 허용되지 않는다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 병합 신청의 적법성

- 사안의 甲은 주위적으로 무효확인을, 예비적으로 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 이는 판례가 허용하는 전형적인 주위적·예비적 병합의 형태이다. 따라서 甲의 소 제기는 적법한 병합으로 인정될 수 있다.

2. 법원의 심리 방향

- 법원은 우선 압류처분의 하자가 중대하고 명백한지 심리한다. 만약 하자가 중대·명백하여 당연무효라면 무효확인판결을 내리고 소송을 종료한다. 그러나 하자가 중대·명백하지는 않으나 위법함이 인정된다면 예비적 청구인 취소소송의 요건(제소기간 등)을 검토한 후 취소판결을 내리게 된다.

V. 결론

- 동일한 처분에 대하여 무효확인을 구하는 청구와 취소를 구하는 청구는 성질상 양립할 수 없는 관계에 있다. 대법원은 이러한 관계를 고려하여 두 청구의 단순 병합이나 선택적 병합은 허용하지 않으나, 주위적·예비적 병합의 형태는 국민의 권리구제 범위를 넓히기 위해 적법한 것으로 인정하고 있다.

이러한 법리는 원고가 하자의 정도를 정확히 판단하기 어려운 실무적 상황을 배려하여 소송 경제와 실효적 권리구제를 동시에 달성하려는 행정쟁송법상의 배려를 반영하고 있다.

<제09장 무효등 확인소송.제07절 청구의 병합과 소의 변경>

[예상][9.07-2]무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

《【문제9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국제 체납을 이유로 압류처분을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음2) 乙이 무효확인소송을 취소소송으로 변경하고자 할 때, 소 변경의 요건 중 하나인 제소기간의 준수 여부를 판단하는 기준 시점에 대하여 행정소송법 규정을 근거로 설명하라.》

<문제9.7의 물음2> 무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 영업정지 처분에 대한 무효확인소송을 제기한 후 해당 처분이 취소사유에 해당함을 이유로 취소소송으로 소를 변경하려 하나, 변경 시점에는 취소소송의 제소기간이 도과한 상황이다. 쟁점으로 <소의 종류 변경 시 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준 시점이 최초 소 제기 시인지 변경 신청 시인지 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정소송법상 소의 변경 규정에 따른 제소기간 준수 여부의 판단 기준 시점을 설명한다.

II. 소의 종류의 변경의 의의 및 요건

1. 의의

- 소의 종류의 변경이란 원고가 청구의 기초에 변경이 없는 한 소송의 계속 중에 소의 종류를 항고소송 상회 간 또는 항고소송과 당사자소송 간에 변경하는 것을 말한다. 乙의 경우 무효확인소송이라는 항고소송을 취소소송이라는 다른 항고소송으로 변경하는 경우에 해당한다.

2. 일반적 요건

(1) 소의 계속과 사실심 변론종결 전

- 구소인 무효확인소송이 법원에 적법하게 계속되어 있어야 하며, 소의 변경 신청은 항소심을 포함한 사실심의 변론종결 전까지 이루어져야 한다.

(2) 청구의 기초의 동일성

- 구소와 신소의 청구 원인이 되는 기초적 사실관계가 동일해야 한다. 영업정지 처분이라는 동일한 행정작용을 대상으로 하므로 이 요건은 충족된다.

(3) 법원의 허가 및 피고의 의견 청취

- 법원은 소의 변경이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 이를 허가하며, 이때 피고의 의견을 들어야 한다.

III. 제소기간의 준수 여부와 기준 시점

1. 행정소송법의 규정 근거

- 행정소송법 제21조 제4항은 소의 종류의 변경이 있는 경우 제14조 제4항 및 제5항의 규정을 준용하도록 하고 있다. 준용되는 제14조 제4항은 피고 경정 시의 제소기간에 관한 규정으로, 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 때에는 처음에 소를 제기한 때에 소가 제기된 것으로 본다고 명시하고 있다.

2. 소급효의 인정

- 위 규정에 따라 乙이 무효확인소송을 취소소송으로 변경하는 신청을 하고 법원이 이를 허가한 경우, 신소인 취소소송은 소를 변경한 시점이 아니라 처음에 무효확인소송을 제기한 시점에 제기된 것으로 간주된다. 이를 소의 변경에 따른 소급효라고 한다.

3. 무효확인소송 제기 당시의 제소기간 준수 필요성

- 다만, 이러한 소급효가 인정되기 위해서는 구소인 무효확인소송 자체가 취소소송의 제소기간(처분이 있음을 안 날로부터 90일 등) 내에 제기되었어야 한다. 만약 처음부터 취소소송의 제소기간을 도과하여 무효확인소송을 제기했다가 나중에 취소소송으로 변경하는 경우에는 소급효를 인정하더라도 신소인 취소소송은 제소기간 도과로 부적법하게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 소 변경 신청 기한

- 사안에서 乙은 소송 심리 중에 소를 변경하고자 하므로 사실심 변론종결 전이라는 시간적 요건을 갖추었다. 乙이 소 변경을 신청하면 법원은 청구의 기초가 동일한지를 판단하여 허가 여부를 결정하게 된다.

2. 제소기간 준수 여부의 판단

- 乙이 소를 변경하려는 현재 시점은 비록 취소소송의 제소기간이 지났으나, 행정소송법 제21조 제4항에 의해 소급효가 인정된다. 따라서 乙이 처음에 무효확인소송을 접수했을 당시에 영업정지 처분에 대한 취소소송 제소기간 내였다면, 현재 변경된 취소소송은 적법하게 제소기간을 준수 것으로 인정된다.

V. 결론

- 무효확인소송을 취소소송으로 변경하는 경우, 신소의 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준 시점은 행정소송법 제21조 제4항 및 제14조 제4항에 의하여 구소인 무효확인소송을 처음에 제기한 때이다. 乙이 무효확인소송을 취소소송의 제소기간 내에 제기했다면, 소 변경 시점에 이미 제소기간이 도과했더라도 소급효에 의해 신소인 취소소송은 적법하게 유지될 수 있다. 이러한 법리는 하자의 정도를 오인하여 소송의 종류를 잘못 선택한 원고에게 소급효를 부여함으로써 제소기간의 도과로 인한 불이익을 방지하고 실효적인 권리구제를 도모하는 데 그 취지가 있다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[예상][10.01-1]부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

《[문제10.1]

부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계에 대해서 논하시오.》

<문제10.1> 부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

I. 부작위위법확인소송의 의의와 절차적 특성

- 행정소송법상 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 부작위 상태가 위법함을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 부존재라는 특수한 상태를 다루므로 제소기간이나 전치절차의 적용에 있어 처분을 대상으로 하는 취소소송과는 다른 법리적 쟁점이 발생한다. 특히, 행정소송법 제38조 제2항이 행정심판전치주의를 규정하는 제18조를 명시적으로 준용하지 않고 있음에도 불구하고, 실무와 이론상 전치주의의 적용이 긍정되는 배경과 그 구체적 실천 방안인 의무이행심판과의 연계성을 고찰할 필요가 있다. 이하에서는 부작위위법확인소송에서 전치주의가 적용되는 근거와 절차적 요건에 대하여 논한다.

II. 행정소송법 제38조 제2항의 조문 해석과 쟁점

1. 조문상 준용 규정의 결여

- 행정소송법 제38조 제2항은 부작위위법확인소송에 준용되는 조항들을 나열하고 있으나, 취소소송의 행정심판전치주의를 규정하고 있는 제18조를 포함하고 있지 않다. 이러한 조문 구조만 보면 문언상 부작위위법확인소송에서는 행정심판을 거칠 필요가 없는 것처럼 보일 수 있다.

2. 입법적 불비와 해석의 필요성

- 조문상 제18조가 누락된 이유에 대하여 입법상의 실수(입법 과오)라는 견해와 부작위의 특성상 처분이 존재하지 않으므로 전치주의를 적용하기 곤란하기 때문이라는 견해가 대립한다. 그러나 개별 법률에서 필요적 전치주의를 규정하고 있는 경우와의 충돌 문제, 그리고 행정소송법 제20조 제2항이 부작위위법확인소송에서 행정심판을 거친 경우의 제소기간을 규정하고 있는 점 등을 고려할 때 해석을 통한 보완이 요구된다.

III. 부작위위법확인소송에서 전치주의가 적용되는 근거

1. 행정소송법 제20조 제2항의 존재

- 행정소송법 제20조 제2항은 부작위위법확인소송에 대하여 제소기간을 적용하지 않으면서도, 다만 행정심판을 거친 경우에는 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 소를 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 법 스스로 부작위위법확인소송에 행정심판 절차가 선행될 수 있음을 예정하고 있는 강력한 근거가 된다.

2. 행정심판법상 부작위에 대한 심판 청구권

- 행정심판법은 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 의무이행심판을 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 행정소송법 제38조 제2항의 준용 규정 누락에도 불구하고, 국민은 행정심판법에 의거하여 부작위 상태에 대해 행정심판을 청구할 권리를 가진다.

3. 필요적 전치주의 규정과의 조화

- 국세, 관세, 도로교통법상의 처분 등 개별 법률에서 `행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거쳐야 한다`고 규정하고 있는 경우, 해당 부작위 역시 그 법률의 적용을 받는 대상이 되므로 전치주의가 적용되는 것으로 해석함이 타당하다. 사법부는 이러한 개별법상의 필요적 전치 규정이 있는 경우 부작위위법확인소송에서도 이를 준수해야 한다고 판단한다.

IV. 의무이행심판과 부작위위법확인소송의 연계

1. 부작위에 대한 행정심판의 형태

- 부작위위법확인소송에 대응하는 행정심판은 부작위위법확인심판이 아니라 의무이행심판이다. 행정심판법은 부작위에 대해 위법 여부만을 확인하는 소극적 심판 대신 행정청에 직접 처분을 명하는 적극적 구제 수단인 의무이행심판을 제도화하고 있기 때문이다.

2. 의무이행심판의 제기 요건

- 당사자는 행정청의 부작위에 대하여 기간의 제한 없이 의무이행심판을 청구할 수 있다. 이때 심판위원회는 부작위가 위법하거나 부당하다고 판단되면 처분을 직접 하거나 처분을 할 것을 명하는 재결을 내리게 된다. 부작위위법확인소송에서 전치주의를 충족하기 위해서는 바로 이 의무이행심판을 거쳐야 한다.

3. 전치 절차로서의 기능

- 부작위위법확인소송에서 행정심판전치주의가 적용되는 경우, 원고는 의무이행심판을 청구하여 기각 재결 등을 받은 후 그 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 소를 제기함으로써 제소기간 요건과 전치 요건을 동시에 충족하게 된다. 만약 의무이행심판에서 인용 재결이 나왔음에도 행정청이 처분을 하지 않는다면, 이는 별도의 부작위 문제이므로 다시 다투어야 한다.

V. 판례 및 실무적 태도

1. 필요적 전치주의 사안에서의 태도

- 판례는 개별 법률이 행정심판전치주의를 채택하고 있는 경우, 부작위위법확인소송이라 하더라도 행정심판을 거치지 않고 소를 제기하면 부적법 각하 판결을 내린다. 법 조문상의 준용 규정 미비보다 개별법상의 강행 규정과 국민의 권리 구제 체계를 우선시하는 입장이다.

2. 제소기간과의 상관관계

- 부작위위법확인소송은 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않으나, 행정심판을 거치게 되면 제소기간의 제한(90일)이 발생한다. 이는 행정심판을 거침으로써 부작위의 위법 여부에 대한 공적인 판단이 한 번 내려졌으므로, 그 이후의 소송 제기는 신속하게 확정되어야 한다는 법적 안정성의 논리가 반영된 것이다.

3. 실무상 유의사항

- 변호사나 당사자는 부작위 상태를 다룰 때 해당 사안이 필요적 전치주의 대상인지를 반드시 확인해야 한다. 만약 국세 사건처럼 전치주의가 필수적인 사안에서 의무이행심판을 거치지 않고 곧바로 부작위위법확인소송을 제기하면 승소 가능성과 상관없이 형식적 요건 미비로 소가 종료될 위험이 크다.

VI. 학설상의 쟁점 및 비판적 검토

1. 준용 규정 누락에 대한 입법론

- 다수설은 행정소송법 제38조 제2항에서 제18조를 누락한 것을 명백한 입법 과오로 본다. 부작위는 처분이 존재하지 않으므로 전치주의를 적용할 객체가 없다는 소수설도 있으나, 행정심판법이 의무이행심판을 통해 부작위를 심판 대상으로 삼고 있는 이상 논거가 부족하다는 평가를 받는다.

2. 전치주의 적용의 정당성

- 행정심판은 행정청 내부의 자율적 통제 기회를 부여하고 사법부의 부담을 경감하는 기능이 있다. 부작위 사안에서도 행정심판위원회가 행정청의 부작위 원인을 분석하여 신속한 처분을 유도할 수 있으므로 전치주의를 적용하는 것이 정책적으로도 타당하다.

3. 의무이행소송 도입과의 관계

- 향후 행정소송법 개정을 통해 의무이행소송이 도입된다면 부작위위법확인소송의 입지는 좁아질 것이다. 현재 부작위위법확인소송과 의무이행심판의 부조화(소송은 확인만, 심판은 이행까지)는 제도의 불균형을 초래하고 있으며, 전치주의 해석 역시 이러한 제도적 과도기에서 발생하는 혼란의 일부이다.

VI 결론

- 행정소송법 제38조 제2항의 명문 규정에도 불구하고 부작위위법확인소송에서 행정심판전치주의가 적용되는 것은 법체계의 통합적 해석과 국민의 실효적 권리 구제를 위한 결과이다. 행정소송법 제20조 제2항이 전치 절차를 거친 경우의 제소기간을 명시하고 있고, 개별 법률이 필요적 전치주의를 요구하는 현실에서 조문상의 준용 규정 누락만을 근거로 전치주의를 부정하는 것은 타당하지 않다. 따라서 부작위 상태에 놓인 당사자는 행정심판법에 의한 의무이행심판을 청구하여 행정청의 응답을 촉구하거나 법적 판단을 받아야 하며, 이를 거친 후에는 엄격해지는 제소기간 내에 소송을 제기해야 한다. 이러한 법리는 행정청의 부작위로부터 국민을 보호하는 동시에 사법 절차의 객관성을 유지하는 균형점이 된다. 결국 부작위위법확인소송에서의 전치주의 문제는 단순한 조문 해석을 넘어 행정구제 제도 전체의 조화로운 운영이라는 관점에서 이해되어야 한다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제01절 행정심판의 대상적격>

[예상][12.01-1]처분의 개념과 행정청의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

《【문제12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 시정권고를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음1) 행정심판법 제2조 제1호에서 규정하는 처분의 개념과 관련하여, 행정청 A의 시정권고가 행정심판의 대상인 처분에 해당하는지 여부를 판례의 입장에 근거하여 논하라.》

<문제12.1의 물음1> 처분의 개념과 행정청 A의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A가 甲에게 관계 법령 위반을 이유로 시정권고를 통지하였고, 甲은 해당 권고가 영업 자유를 제한하는 행정심판 대상 처분에 해당한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판의 대상이 되는 처분의 개념과 비권력적 행정작용인 시정권고가 처분에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정청 A의 시정권고가 행정심판법상 처분에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 행정심판의 대상으로서의 처분

1. 처분의 개념

- 행정심판법 제2조 제1호는 처분을 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라고 정의하고 있다. 이는 행정소송법상의 처분 개념과 동일하게 해석되는 것이 일반적이다.

2. 처분성의 판단 기준

- 판례는 처분인지 여부를 판단함에 있어 그 행위의 성질·태양 및 목적, 응답의무의 존부, 주권자인 국민의 권리의무에 직접 관계되는 것인지 여부, 그리고 당해 행정작용의 실질적 영향력 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단한다. 특히, 최근 판례는 국민의 권익구제의 폭을 넓히기 위하여 형식적인 법적 효력 유무에만 집착하지 않고 실질적인 불이익 여부를 중시하는 경향이 있다.

III. 시정권고의 행정지도적 성격과 처분성

1. 행정지도와 시정권고의 일반적 성격

- 행정절차법 제2조 제1호에 따르면 행정지도는 행정기관이 그 직무 범위 안에서 일정한 행정 목적을 달성하기 위하여 특정인에게 일정한 작위 또는 부작위를 권고, 금지, 안내하는 등의 비권력적 사실행위를 말한다. 시정권고는 명칭상 권고의 형식을 띠고 있어 원칙적으로 상대방의 임의적인 협력을 전제로 하므로 법적 구속력이 없는 행정지도에 해당한다.

2. 처분성 인정 여부에 관한 판례의 입장

(1) 원칙적 부정

- 전통적 판례는 행정지도가 상대방의 자발적 동의를 기초로 하는 것이며 그 자체만으로는 어떠한 법적 권리나 의무를 설정하지 않으므로 처분성이 없다고 보았다. 단순히 사실상의 강제력을 갖는 것만으로는 부족하다는 취지이다.

(2) 예외적 인정(실질적 판단)

- 최근 판례는 행정지도가 형식상으로는 권고의 형태를 띠더라도 실질적으로 법령의 위반을 전제로 하고, 이를 따르지 않을 경우 후속적인 제재 처분(영업정지, 과태료 부과 등)이 예정되어 있어 사실상 강제력을 행사하는 경우에는 처분성을 인정한다. 즉, 당해 행위가 상대방에게 법적 불이익을 수인하도록 강요하는 효과가 있다면 행정쟁송의 대상으로 삼을 수 있다는 것이다.

(3) 구체적 사례(국가인권위원회 등의 권고)

- 국가인권위원회의 성희롱 결정 및 시정권고와 관련하여 판례는 비록 권고의 형식을 취하고 있으나, 당사자의 명예에 직접적인 타격을 가하고 향후 신분상 불이익을 초래할 가능성이 크다는 점을 근거로 처분성을 인정한 바 있다.

IV. 사안의 적용

1. 시정권고의 실질적 영향력 분석

- 사안에서 행정청 A의 시정권고는 관계 법령 위반을 이유로 하고 있다. 법령 위반을 이유로 한 권고는 통상적으로 이를 이행하지 않을 경우 행정청이 강제적인 제재 처분으로 나아갈 것임을 예고하는 전단계 행위로서의 성격을 갖는다.

2. 甲의 영업의 자유 제한 여부

- 甲은 해당 권고가 사실상의 강제력을 가져 영업의 자유를 제한한다고 주장한다. 만약 이 시정권고가 단순한 안내에 그치지 않고, 명단 공개나 후속 제재 처분의 직접적인 요건이 되는 등 甲에게 실질적인 법적 지위의 불안이나 불이익을 초래한다면 행정심판법상 처분으로 보아 다룰 수 있어야 한다.

3. 소결

- 판례의 법리에 따라 때, 행정청 A의 시정권고가 단순히 권고의 수준을 넘어 상대방에게 법적 의무 이행을 강요하는 실질적 효과를 지닌다면 이는 행정심판의 대상인 처분에 해당한다고 보아야 한다.

V. 결론

- 행정심판의 대상인 처분은 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 공권력 행사를 의미한다. 행정청 A의 시정권고는 형식적으로는 비권력적 사실행위인 행정지도에 해당하여 원칙적으로 처분성이 부정되나, 판례는 그 실질적인 영향력을 고려하여 예외적으로 처분성을 인정하고 있다. 따라서 사안의 시정권고가 법령 위반을 전제로 하여 甲에게 사실상의 복종을 강요하고 불이행 시 제재가 예정되어 있는 등 실질적인 불이익을 주는 작용이라면, 甲은 이에 대하여 행정심판을 청구하여 그 적법성을 다툴 수 있다. 이러한 법리는 행정 작용의 형식이 점차 다양해짐에 따라 국민의 권익이 사각지대에 놓이지 않도록 처분의 개념을 유연하게 해석하려는 현대 행정쟁송법의 흐름과 궤를 같이한다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제01절 행정심판의 대상적격>

[예상][12.01-2]부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

《【문제12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 시정권고를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음2) 乙이 행정청 B의 무반응에 대하여 제기할 수 있는 행정심판의 종류를 제시하고, 행정심판법상 부작위가 성립하기 위한 요건을 설명하라. 또한, 丙이 행정심판법에 따른 행정심판을 청구할 수 없는 예외적인 사유가 존재하는지 행정심판법 제3조를 중심으로 서술하라.》

<문제12.1의 물음2> 부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청 B가 인허가 신청에 대하여 상당한 기간 동안 아무런 처분을 하지 않는 부작위 상태에 있고, 丙은 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판 청구 가능 여부가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판의 요건과 행정심판법 제3조에 따른 행정심판 청구 제한 사유의 존재 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기할 수 있는 부작위에 대한 행정심판의 종류와 성립요건 및 丙이 행정심판을 청구할 수 없는 사유가 존재하는지 서술한다.

II. 부작위에 대한 행정심판의 종류 및 성립 요건

1. 행정심판의 종류

- 행정청의 부작위에 대하여 乙이 제기할 수 있는 행정심판은 크게 의무이행심판이다. 행정심판법 제5조 제3호에 따르면 의무이행심판은 행정청의 부당하거나 위법한 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 구하는 심판이다. 현행 행정심판법은 부작위위법확인심판을 별도로 두지 않고 의무이행심판으로 통합하여 운영하고 있다.

2. 부작위의 성립 요건

(1) 당사자의 신청

- 부작위가 성립하기 위해서는 먼저 법령에 근거하여 행정청에 대하여 특정한 처분을 구하는 당사자의 적법한 신청이 있어야 한다. 사안에서 乙이 행정청 B에게 인허가를 신청한 사실이 이에 해당한다.

(2) 행정청의 처분 의무

- 행정청에게 신청에 대하여 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재해야 한다. 이는 법령상 명시적인 의무뿐만 아니라 해석상 응답 의무가 인정되는 경우도 포함한다.

(3) 상당한 기간의 경과

- 행정청이 신청을 수리한 후 사회통념상 해당 처분을 하기에 충분한 상당한 기간이 경과하였어야 한다. 사안에서도 상당한 기간이 경과하였음이 명시되어 있다.

(4) 행정청의 무반응

- 행정청이 인가·허가 등의 긍정적 처분뿐만 아니라 거부처분과 같은 부정적 처분조차 하지 않은 상태여야 한다. 만약 거부처분을 하였다면 이는 부작위가 아니라 거부처분 취소심판이나 의무이행심판의 대상이 된다.

III. 행정심판 청구의 예외적 사유 [행정심판법 제3조]

1. 행정심판법 제3조의 취지

- 행정심판법 제3조 제1항은 모든 처분과 부작위에 대하여 행정심판을 제기할 수 있음을 원칙으로 하되, 사안의 성질상 행정심판법에 따른 심판 절차를 거치는 것이 부적절하거나 특별한 불복 절차가 마련되어 있는 경우에는 예외를 인정하고 있다.

2. 행정심판법 적용 제외 대상 [제3조 제2항]

- 행정심판법 제3조 제2항은 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판을 제기할 수 없다고 규정한다. 그러나 丙의 사례는 중앙선거관리위원회 위원장의 처분이므로 이에 해당하지 않는다.

3. 다른 법률에 따른 특별한 불복 절차

- 특정 기관의 행위에 대하여는 헌법적 지위나 절차의 특수성을 고려하여 행정심판법에 따른 행정심판 대신 별도의 특별행정심판이나 소송 절차를 허용하는 경우가 있다.

(1) 선거관리위원회 처분의 특수성

- 중앙선거관리위원회 위원장의 처분은 그 기관의 독립성과 전문성을 고려할 때 일반 행정심판위원회의 심리 대상으로 삼기에 부적절할 수 있다.

(2) 丙의 사례에 대한 적용

- 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분과 같은 인사에 관한 사항은 국가공무원법 등에 따라 소청심사라는 특별한 행정심판 절차를 거쳐야 하거나, 기관의 특성상 행정심판법의 일반적 절차가 배제될 수 있다. 특히, 행정심판법 제3조 제1항은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 예외로 두고 있는데, 선거관리위원회 위원장의 행위 등 헌법기관의 처분에 대해서는 해당 기관 내부에 설치된 위원회나 특별법에 따른 절차를 따르도록 규정된 경우가 많으므로 丙은 행정심판법상의 일반 행정심판을 청구할 수 없는 예외적 상황에 처할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 구제 수단

- 乙은 행정청 B의 인허가 신청에 대한 무반응에 대하여 의무이행심판을 제기할 수 있다. 사안은 乙의 신청이 있었고, 상당한 기간이 지났으며, 행정청 B가 아무런 응답을 하지 않고 있으므로 행정심판법상 부작위 요건을 모두 충족한다. 따라서 乙은 행정심판위원회에 처분을 이행할 것을 구하는 심판을 청구할 수 있다.

2. 丙의 행정심판 청구 가능성 검토

- 丙이 다투고자 하는 중앙선거관리위원회 위원장의 처분은 행정심판법 제3조 제1항의 예외 사유에 해당할 가능성이 매우 높다. 헌법기관인 선거관리위원회의 처분은 그 독립성을 존중하여 일반 행정심판위원회의 감독을 받지 않으며, 소청심사와 같은 별도의 행정심판 절차가 마련되어 있거나 직접 행정소송으로 다투어야 할 사안에 해당하므로 丙이 행정심판법에 따른 일반 행정심판을 청구하는 것은 부적법할 것으로 판단된다.

V. 결론

- 乙은 행정청 B의 부작위에 대하여 의무이행심판을 통해 구제받을 수 있으며, 이는 행정청의 처분 의무와 상당 기간의 무응답이라는 부작위 요건을 충족하였기 때문이다. 반면 丙의 경우 처분청이 중앙선거관리위원회 위원장이라는 점과 파면이라는 인사 처분의 특성상, 행정심판법 제3조 제1항이 규정하는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 등에 해당하여 일반 행정심판법에 따른 심판 청구는 허용되지 않을 것이다. 이러한 법리는 행정청의 무분응에 대한 실효적 구제 수단을 제공함과 동시에, 헌법상 독립기관이나 대통령의 처분 등에 대해서는 일반적 심판 절차의 예외를 설정함으로써 권력분립과 행정의 특수성을 조화시키려는 취지를 담고 있다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

[예상][12.03-1]불고지에 따른 행정심판의 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

《【문제12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 영업정지 1개월 처분을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다(불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음1) 甲이 2025년 9월 10일에 행정심판을 청구하는 경우, 행정심판법 제27조에 규정된 행정심판 청구기간의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 특례를 중심으로 해당 청구가 적법한지 여부를 논하라.》

<문제12.3의 물음1> 불고지에 따른 행정심판 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A는 甲에게 영업정지 1개월 처분을 하면서 행정심판 청구기간 등에 관한 사항을 고지하지 않았고, 甲은 처분이 있는 날로부터 4개월이 경과한 후 행정심판을 청구하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 청구기간의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 청구기간의 특례가 적용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 행정심판 청구가 청구기간을 준수하여 적법한지 논한다.

II. 행정심판 청구기간의 원칙

1. 주관적 청구기간

- 행정심판법 제27조 제1항에 따라 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 여기서 처분이 있음을 알게 된 날이란 통지나 공고 등 처분이 있음을 현실적으로 안 날을 의미한다.

2. 객관적 청구기간

- 동법 제27조 제3항에 따라 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 이는 처분이 있음을 알지 못한 경우에도 적용되는 절대적인 기간이다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 예외적으로 인정될 수 있다.

3. 기간의 성격

- 행정심판 청구기간은 불변기간이 아니나(심판법상 명시적 규정 없음), 기간이 경과하면 해당 처분을 더 이상 다툴 수 없는 확정력(불가쟁력)이 발생하므로 소송요건의 하나로서 엄격히 준수되어야 한다.

III. 행정청의 불고지에 따른 청구기간의 특례

1. 고지제도의 의의 [행정심판법 제58조]

- 행정청은 처분을 할 때 상대방에게 행정심판 청구 가능 여부, 청구 절차 및 기간 등을 알려야 할 의무가 있다. 이는 국민의 알 권리를 보장하고 행정쟁송의 기회를 실효적으로 제공하기 위함이다.

2. 불고지의 효과 [행정심판법 제27조 제6항]

- 행정청이 처분을 하면서 심판 청구 기간을 알리지 아니한 경우(불고지)에는 동법 제27조 제3항에 따른 기간, 즉 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 심판 청구를 할 수 있다.

3. 특례의 취지

- 행정청의 고지 의무 위반으로 인해 청구인이 90일이라는 단기적인 주관적 청구기간을 지키지 못한 책임을 청구인에게 전가하지 않기 위한 것이다. 따라서 불고지의 경우에는 주관적 청구기간(90일)은 적용되지 않고 오직 객관적 청구기간(180일)만이 적용된다.

IV. 사안의 적용

1. 주관적 청구기간 준수 여부 검토

- 甲은 2025년 5월 1일에 처분서를 수령하였으므로 처분이 있음을 안 날은 2025년 5월 1일이다. 원칙적인 청구기간인 90일을 적용하면 2025년 7월 말경에 기간이 만료되므로, 90일이 지난 2025년 9월 10일의 청구는 원칙적으로 부적법하다.

2. 불고지 특례의 적용

- 그러나 행정청 A는 처분 시 청구 기간을 전혀 기재하지 않았다. 행정심판법 제27조 제6항에 따라 甲에게는 90일의 기간이 적용되지 않고 처분이 있었던 날부터 180일의 기간이 적용된다.

3. 구체적인 기간 계산

- 처분이 있었던 날인 2025년 5월 1일부터 180일을 계산하면 2025년 10월 하순경까지 청구가 가능하다. 甲이 행정심판을 청구한 날은 2025년 9월 10일이므로, 이는 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 해당한다.

V. 결론

- 행정심판법은 행정청의 고지 의무 이행을 담보하고 국민의 쟁송권을 보호하기 위하여 불고지 시 청구기간의 특례를 두고 있다. 사안에서 행정청 A의 불고지로 인해 甲에게는 처분이 있었던 날부터 180일의 청구기간이 보장된다. 甲이 2025년 9월 10일에 제기한 행정심판 청구는 처분이 있음을 안 날부터 90일은 경과하였으나, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 제기된 것이므로 청구기간을 준수한 적법한 청구에 해당한다. 이러한 법리는 행정청의 절차적 의무 위반이 국민의 실질적인 권리 구제 기회를 박탈하지 않도록 차단하는 장치로서, 행정의 투명성과 책임성을 강조하는 행정심판법의 기본 정신을 반영하고 있다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

[예상][12.03-2]피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

《【문제12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 영업정지 1개월 처분을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다(불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음2) 乙의 사례와 같이 피청구인을 잘못 지정하여 행정심판을 청구한 경우, 행정심판법상 어떠한 구제 절차가 마련되어 있는지 피청구인의 경정 제도를 중심으로 설명하라.》

<문제12.3의 물음2> 피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청 B의 인허가 거부처분에 대하여 행정심판을 청구하면서 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 지정하여 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정심판 청구 시 피청구인을 잘못 지정한 경우 이를 보정할 수 있는 행정심판법상 피청구인의 경정 제도의 요건과 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 잘못된 피청구인 지정에 대한 구제 절차로서 피청구인의 경정 제도에 대해 설명한다.

II. 피청구인의 경정 제도 일반론

1. 의의

- 피청구인의 경정이란 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 원래의 피청구인을 물러나게 하고 정당한 피청구인으로 교체하는 것을 말한다. 이는 청구인의 단순한 실수로 인하여 본안 심리도 받지 못하고 권리구제 기회를 박탈당하는 불합리한 결과를 방지하기 위한 제도이다.

2. 법적 근거

- 행정심판법 제17조는 피청구인의 경정에 관하여 규정하고 있다. 특히 제1항은 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우 위원회가 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 피청구인을 경정할 수 있음을 명시하고 있다.

III. 피청구인 경정의 요건 및 절차

1. 경정 요건

(1) 피청구인의 오지정

- 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 것이 명백해야 한다. 사안의 乙과 같이 처분청인 B 대신 행정심판위원회를 피청구인으로 기재한 경우는 전형적인 오지정에 해당한다.

(2) 심판청구의 계속

- 해당 행정심판이 위원회에 계속 중이어야 한다. 즉, 아직 심결이 내려지기 전이라면 사실심 단계에서 언제든지 가능하다.

2. 경정 절차

(1) 신청 또는 직권에 의한 경정

- 청구인이 스스로 잘못을 깨닫고 경정을 신청할 수 있을 뿐만 아니라, 행정심판위원회 역시 오지정이 명백하다고 판단되면 청구인의 신청이 없더라도 직권으로 경정을 결정할 수 있다.

(2) 위원회의 결정

-위원회는 경정 사유가 인정되면 경정 결정을 내린다. 이때 위원회는 종전의 피청구인과 새로운 피청구인 및 청구인에게 그 사실을 통지해야 한다.

IV. 경정의 효과 및 제소기간과의 관계

1. 소급효의 인정

- 행정심판법 제17조 제3항에 따라 피청구인의 경정 결정이 있으면 새로운 피청구인에 대한 심판청구는 처음에 심판청구를 한 때에 제기된 것으로 본다. 즉, 피청구인을 잘못 지정했더라도 처음에 청구서를 제출한 시점을 기준으로 청구 기간의 준수 여부를 판단하므로 乙에게 매우 유리한 규정이다.

2. 종전 피청구인에 대한 소의 종료

- 새로운 피청구인으로서의 경정이 확정되면 종전의 잘못 지정된 피청구인에 대한 심판청구는 취하된 것으로 간주되어 소송 절차에서 탈퇴하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 구제 가능성

- 乙은 비록 피청구인을 행정심판위원회로 잘못 기재하였으나, 이는 행정심판법 제17조에 따른 경정 사유에 해당한다. 따라서 乙은 스스로 피청구인 경정 신청을 하거나, 위원회가 직권으로 행정청 B를 피청구인으로 변경하는 결정을 내림으로써 구제받을 수 있다.

2. 청구기간 준수 여부의 확정

- 乙이 처음에 행정심판위원회에 청구서를 제출한 시점이 거부처분에 대한 행정심판 청구기간 내였다면, 추후 피청구인이 행정청 B로 경정되더라도 처음에 제출한 날짜를 기준으로 기간 준수 여부를 판단하므로 제소기간 도과 문제는 발생하지 않는다.

VI. 결론

- 행정심판법상 피청구인의 경정 제도는 청구인의 절차적 실수를 교정해 주는 핵심적인 구제 수단이다. 乙의 사례와 같이 피청구인을 오인하여 청구한 경우, 위원회의 직권 또는 乙의 신청에 의한 경정 결정을 통해 정당한 처분청인 B를 상대로 심판 절차를 계속 진행할 수 있다. 이러한 제도는 행정심판이 단순한 법적 쟁송을 넘어 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 간이·신속한 구제 절차로서 기능하게 하는 밑거름이 된다. 이러한 법리는 형식주의를 탈피하여 실질적 법치주의를 실현하고자 하는 행정쟁송법의 기본 원리를 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.

《【문제13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다며 위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음1) 행정심판법 제39조에서 규정하는 직권심리주의의 의미와 범위에 비추어 볼 때, 행정심판위원회가 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여 심리할 수 있는지 여부와 그 한계에 대하여 서술하라.》

<문제13.1의 물음1> 직권심리주의의 의미와 범위 및 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정심판위원회는 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대하여 직권으로 조사하고 관련 증거를 수집하였으며, 甲은 이러한 직권심리의 범위와 한계가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 직권심리주의의 의미와 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 가능 여부 및 그 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판위원회의 직권심리가 허용되는 범위와 한계에 대해 서술한다.

II. 행정심판의 심리 원칙과 직권심리주의

1. 심리 원칙의 구조

- 행정심판의 심리는 당사자의 주장과 증거제출을 기초로 하는 당사자주의를 원칙으로 하되, 행정의 적법성 확보와 공익 실현이라는 목적을 위해 직권주의적 요소를 가미하고 있다. 이를 직권탐지주의가 가미된 변론주의라고 한다.

2. 직권심리주의의 의의

- 행정심판법 제39조는 위원회로 하여금 사건의 진상을 파악하여 객관적이고 공정한 재결을 내릴 수 있도록 심리의 능동성을 부여한다. 이는 법률 지식이 부족한 청구인을 보호하고 처분의 적법성을 실질적으로 심사하기 위한 장치이다.

III. 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 가능성

1. 심리의 범위

- 직권심리는 당사자가 제기한 심판청구의 대상이 되는 처분의 위법·부당성 여부를 판단하기 위한 범위 내에서 이루어진다. 판례는 행정소송과 마찬가지로 행정심판에서도 처분의 동일성이 유지되는 범위 내에서는 당사자가 명시적으로 주장하지 않은 사유라도 기록에 나타난 자료를 바탕으로 심리할 수 있다는 입장이다.

2. 심리 가능한 사실의 성격

- 위원회가 심리할 수 있는 주장하지 않은 사실은 처분의 적법성을 판단하는 데 기초가 되는 사실관계나 증거를 의미한다. 즉, 청구인이 주장하는 위법 사유를 뒷받침하거나 반박하기 위해 필요한 객관적 정황들을 위원회가 직접 탐지할 수 있다.

IV. 직권심리주의의 한계

1. 처분의 동일성 유지

- 직권심리는 청구의 대상이 된 당해 처분의 범위를 벗어날 수 없다. 즉, 처분의 기초가 되는 기본적 사실관계의 동일성이 없는 전혀 새로운 처분 사유를 위원회가 임의로 찾아내어 재결의 근거로 삼는 것은 허용되지 않는다.

2. 불이익변경금지의 원칙

- 직권심리의 결과 처분이 위법함을 발견하더라도, 재결은 심판청구의 대상이 된 처분보다 청구인에게 불리한 내용으로 결정될 수 없다(행정심판법 제47조 제2항). 직권심리가 청구인의 지위를 악화시키는 도구로 사용되어서는 안 된다는 취지이다.

3. 당사자의 방어권 보장과 석명권

- 위원회가 직권으로 사실을 조사한 경우, 그 결과에 대하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 당사자가 전혀 예상하지 못한 사실을 근거로 재결하는 것은 방어권을 침해하는 기습적 판단이 될 수 있으므로, 위원회는 관련 사항에 대해 석명권을 행사하여 당사자의 의견을 들어야 한다.

V. 사안의 적용

1. 위원회의 조사 행위의 적정성

- 사안에서 위원회가 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계 파악이 어려워 직접 조사를 실시한 것은 행정심판법 제39조에 따른 정당한 직권심리 범위 내에 있다. 특히 성매매 알선이라는 중대한 사유에 대한 처분의 적법성을 따지기 위해 실체적 진실을 규명하는 것은 위원회의 의무이기도 하다.

2. 심리 범위의 한계 준수 여부

- 다만 위원회는 조사한 새로운 사실관계가 영업허가 취소처분이라는 기존 처분의 기본적 사실관계 동일성 내에 있는지 확인해야 한다. 또한 조사된 사실이 甲에게 불리한 증거로 사용될 경우, 반드시 甲에게 그에 대한 반박이나 의견 진술의 기회를 부여함으로써 절차적 정당성을 확보해야 한다.

VI. 결론

- 행정심판법상 직권심리주의는 행정청의 처분에 대한 실체적 적법성을 확보하기 위해 인정되는 원칙이다. 따라서 위원회는 사안의 진상을 명확히 하기 위해 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여도 심리하고 조사할 수 있다. 그러나 이러한 권한은 처분의 동일성을 유지하는 범위 내로 제한되며, 당사자의 방어권을 보장하기 위해 고지 및 의견 진술의 기회를 부여해야 한다는 절차적 한계를 가진다. 사안의 위원회는 조사한 사실을 토대로 재결하되, 甲에게 해당 조사 결과에 대한 의견을 묻는 석명 절차를 거침으로써 직권심리의 한계를 준수해야 한다.

《【문제13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다며 위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음2) 행정심판법 제40조에 따른 구술심리와 서면심리의 관계를 설명하고, 甲이 구술심리를 신청하였음에도 불구하고 위원회가 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적인 사유에 대하여 기술하라.》

<문제13.1의 물음2> 구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청 거절의 예외적 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 자신의 주장을 직접 진술하기 위하여 행정심판위원회에 구술심리를 신청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면심리만으로 재결하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청에도 불구하고 서면심리만으로 재결할 수 있는 예외 사유>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 구술심리 신청에 대한 행정심판위원회의 서면심리 가능 여부를 중심으로 기술한다.

II. 구술심리와 서면심리의 관계

1. 심리 방식의 의의

(1) 서면심리

- 당사자가 제출한 심판청구서, 답변서, 증거서류 등 서면 자료만을 바탕으로 사건을 파악하고 판단하는 방식이다. 신속한 처리가 가능하고 비용이 적게 든다는 장점이 있다.

(2) 구술심리

- 당사자나 대리인이 위원회에 직접 출석하여 말로 주장하고 진술하는 방식이다. 심판위원들이 당사자의 목소리를 직접 듣고 의문점을 즉석에서 확인할 수 있어 실제적 진실 규명과 당사자의 절차적 만족도 제고에 유리하다.

2. 행정심판법의 원칙(병행주의와 구술심리 신청권)

- 행정소송이 구술심리를 원칙으로 하는 것과 달리, 행정심판법 제40조 제1항은 행정심판의 심리는 구술심리나 서면심리로 한다고 규정하여 양자를 선택적으로 병용할 수 있음을 밝히고 있다. 다만, 동조 제2항은 당사자가 구술심리를 신청하면 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다고 규정함으로써, 당사자가 원하는 경우 구술심리를 원칙적인 심리 방식으로 보장하고 있다.

III. 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적 사유

- 행정심판위원회는 당사자의 구술심리 신청이 있더라도 다음의 경우에는 예외적으로 서면심리만으로 재결할 수 있다.

1. 서면심리만으로 충분하다고 인정되는 경우

- 사건의 쟁점이 법률적 해석에 국한되거나, 이미 제출된 서면 자료와 증거만으로도 처분의 위법·부당 여부가 객관적이고 명백하게 드러나는 경우이다. 굳이 당사자를 출석시켜 진술을 듣지 않더라도 실제적 진실을 파악하는 데 지장이 없다고 위원회가 판단할 때 해당한다.

2. 신청이 부적절하거나 지연 목적이 명백한 경우

- 당사자의 신청이 오로지 재결을 지연시키기 위한 목적이거나, 이미 충분한 진술 기회가 주어졌음에도 반복적인 주장을 위해 출석을 요구하는 등 심리의 효율성을 저해한다고 판단되는 경우 위원회는 이를 거부할 수 있다.

3. 절차적 경제와 효율성 고려

- 행정심판은 소송에 비해 간이하고 신속한 구제를 목적으로 하므로, 사안의 경중이나 복잡성에 비추어 구술심리에 소요되는 행정적 비용과 시간이 과다하다고 인정될 때 서면심리를 선택할 수 있는 재량이 위원회에 부여된다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 구술심리 신청권의 성격

- 甲은 자신의 억울함을 풀기 위해 구술심리를 명시적으로 신청하였다. 행정심판법 제40조 제2항의 취지상 위원회는 특별한 사정이 없는 한 甲에게 출석하여 진술할 기회를 부여해야 한다.

2. 위원회의 서면심리 결정의 정당성 검토

- 위원회가 사건이 명백하다는 이유로 서면심리만 하려는 것은 법에서 정한 예외 사유 중 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우에 해당한다고 주장하는 것이다. 그러나 영업허가 취소라는 중익적 처분이고, 甲이 전혀 몰랐던 사실이라며 주관적 사정을 강력히 주장하고 있는 점을 고려할 때, 단순히 경찰 통보 내용만으로 사건이 명백하다고 단정하여 구술심리를 거부하는 것은 甲의 절차적 권리를 과도하게 제한할 우려가 있다.

3. 위원회의 재량과 한계

- 위원회가 서면심리를 강행할 수는 있으나, 이는 객관적으로 보아 서면만으로 충분하다는 판단이 합리적이어야 한다. 만약 甲의 주장에 대한 사실관계 확인이 더 필요하거나 감정적 억울함에 대한 소명이 처분의 부당성 판단(재량권 남용 등)에 영향을 미칠 수 있다면, 위원회는 구술심리 신청을 받아들이는 것이 타당하다.

V. 결론

- 행정심판법상 구술심리와 서면심리는 병행될 수 있으나, 당사자의 신청이 있는 경우에는 구술심리를 하는 것이 원칙이다. 다만 위원회는 서면만으로도 처분의 적법성을 판단하기에 충분하다고 인정되는 예외적인 경우에 한하여 이를 거부하고 서면심리만으로 재결할 수 있다. 사안에서 위원회가 甲의 신청을 거절하고 서면심리만으로 결정하고자 한다면, 그것이 단순한 편의주의가 아니라 제출된 자료만으로도 충분히 객관적인 판단이 가능하다는 합리

적 근거가 뒷받침되어야 한다. 이러한 판단은 행정심판의 신속성과 당사자의 절차적 권리 보장이라는 두 가치를 조화시키려는 노력의 일환이며, 특히 침익적 처분의 경우 당사자의 진술권을 폭넓게 보장하는 것이 실질적 법치주의에 부합한다.